

제1편 행정법 총론

제1장 행정법의 의의

제1절 행정법의 개념

<★★> 공법과 사법의 구별

주.중.이.복

구별필요성 : 공법인지 사법인지? > 행정법or민법, 행소or민소
달라짐

학 : ①법률관계의 주체를 기준으로 하는 주체설 ②법률관계가
상하관계인지 대등관계인지 기준으로 하는 종속설 ③ 법의
규율 목적을 기준으로 하는 이익설 ④ 이러한 기준들을 모
두 고려하는 복수기준설이 통설

판 : 행정청이 공권력을 가진 우월적 지위에서 행한 것은 공법
관계, 사경제주체로서 행하는 행위는 사법관계로 판단한다.

검 : 다양한 법률관계를 고려할 때, 복수기준설이 타당

※ 사립학교의 장의 전학처분을 행정청의 처분으로 볼 수 있는
지 여부

判例는 사립학교 재학관계는 공법상 권력관계라 할 수 없으므로 민사소송절차에 의하여야 한다고 보아 처분성을 부정

<★★> 공법상 부당이득반환청구 사권설

문 : 공법상 원인에 의한 부이반- 공권? 사권?

학 : ① 공법상의 원인에 의하여 급부된 것이라도 부당이득의
문제가 발생한 때에는 아무런 법률상 원인이 없는 것이고
부당이득반환제도는 사법상의 제도이니 사권이라는 사권
설 ②공법상의 원인에 기하여 생긴 결과를 조정하기 위한
제도이므로 공권이라는 공권설

판 : 조세부과처분 무효 전제 세금 반환 청구. 민사상 부당이득
반환청구, 민사소송절차. 사권설

<★> 통치행위

사.권.통, 고도의 정치성, 인정을 지극히 신중하게

의: <현재> 통치행위란 고도의 정치적 결단에 의하여 발
동되는 행위이고 그 결단을 존중하여야 할 필요성이 있
는 행위

학 : ①통치행위는 법원이 스스로 사법심사를 자제하기에
사법심사의 대상이 되지 않는다는 사법자제설
② 법원이 정치문제를 심사하는 것은 사법권에 존재
하는 재재적 한계를 넘어서기에 사법심사의 대상이
되지 않는다는 권력분립설
③ 현대국가에서는 모든 국가작용이 사법심사의 대
상이 되어야 한다는 통치행위이론 부정설

판 : 고도의 정치성을 띤 국가행위에 대해서는 법원 스스로
심사대상에서 제외하는 영역이 있을 수 있으나,
과도한 사법심사의 자제가 기본권을 보장하고 법치
주의 이념을 구현하여야 할 법원의 책무를 태만히
하거나 포기하는 것이 되지 않도록 그 인정을 지극
히 신중하게 하여야 한다

* 파병결정o , 비상계엄선포행위o 남북정상회담 개최 o,
서훈취소 x

제2절 행정법의 일반원칙
제2절 행정법의 일반원칙 (비.평.자.신.부)

<★> 자기구속의 원칙 [3회]

관.동.위 선례필요설(행정관행설)

의 :행정관행과 동일 사안에서 동일 결정을 해야 한다는
원칙으로 평등원칙의 파생원칙. (관행, 동일, 위법x)

행정관행 필요성: (判例) 행정처분이 행정조직 내부에서
만 효력을 가지는 행정규칙을 위반하였다고 하여
위법하게 되는 것은 아니지만. 그 행정규칙이 정한
바에 따라 되풀이 시행되어 행정관행이 이루어지게
되면 행정기관은 자기구속을 받게 되므로, 그에 반
하는 처분은 특별한 사정이 없는 한 재량권을 일탈
남용한 위법한 처분. 선례필요설(행정관행설)

판) 위법한 행정처분- 자기구속력 X

☞평등의 원칙의 파생원칙이므로 자기구속을 먼저 검토.

<성실의무, 권한남용금지의 원칙>

행기법 제11조 제1항, 제2항

<★★> 비례의 원칙 [3, 5회. 14-2] 적.필.상

조 : 행기법 제10조

위반여부 :

① 행정목적의 달성하는 데 유효하고 적절할 것(적합
성),

② 행정목적의 달성하는 데 필요한 최소한도에 그칠 것
(필요성)

③ 행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용
이 의도하는 공익보다 크지 아니할 것(상당성, 협의의
비례원칙)

☞ 헌법과 달리 목적의 정당성 검토 X

☞ 기록형에서 정삼참작 사유 몇 개인지로 채점함

☞ 최근 판례가 적, 필, 상 나누어 검토하고 있음

2. 최신판례

가. 코로나 집합금지 사건(대법원 2024. 7. 18. 선고
2022두43528 전원합의체 판결) → 비례·평등의 원칙을
위반하여 종교의 자유를 침해 X

<★★> 신뢰보호의 원칙 [23-3, 21-1]

공, 귀, 어, 반, 침

의 : 행정청은 공익 또는 제3자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호해야 한다(행기법 제12조 제1항)

요건: ① 행정청의 선행조치로서 공적 견해표명, ② 귀책사유 없는 신뢰, ③ 신뢰에 기초한 어떠한 행위, ④ 견해표명에 반하는 처분, ⑤ 신뢰한 개인의 이익 침해
귀책사유 없는 보호가치 있는 신뢰: 관계인의 적극적 부정, 고의 또는 중과실 > 귀책사유 o

* 신뢰보호의 한계: 합법성의 원칙 또는 공익과의 충돌

문 : 신뢰보호 vs 법률적합성

학 : ① 법률적합성우위설, ② 이익형량설(동위설)

판 : 이익형량설(동위설)

검: 신뢰보호원칙과 법률적합성원칙은 법치주의의 기본원리로서 동위적 관계에 있으므로 이익형량설이 타당

☞ 부진정소급입법의 제한

*신뢰보호 원칙 부정 키워드: '법령개정'의 예측성, 국가에 의해 유인된 신뢰x, 법령의 기회활용에 불과

<실권의 법리 위반 여부> 박도원 7

실권의 법리는 행정청에게 권리행사 가능성이 있음에도 장기간 그 권리를 불행사한 경우 그 권리를 실효시키는 법리로서(행정기본법 제12조 제2항), 신뢰보호원칙의 파생원칙이다.

<★> 부당결부금지의 원칙 [3회, 22-1]

의 : 행정청은 행정작용을 할 때 상대방에게 해당 행정작용과 실질적인 관련이 없는 의무를 부과해서는 아니 된다(행정기본법 제13조)

☞ 주로 부관의 한계와 관련하여 적용됨

법치행정의 원칙 및 법률유보의 원칙

법치행정의 원칙:

행정작용은 법률에 위반되어서는 x, 권리를 제한, 의무를 부과하는 경우 > 법률에 근거 (행기 제8조)

법률유보의 원칙 : 국가공동체와 그 구성원에게 기본적으로 고도 중요한 의미를 갖는 영역, 특히 기본권 관련 > 입법자 스스로 그 본질적 사항에 대하여 결정, 즉 의회유보원칙까지 내포. (全畵)

<★> 평등의 원칙 [3회] 동. 차. 합

의의 : 합리적 이유 없이 국민 차별x

조문 : 행기법 제9조, 헌법 제11조

심사기준 : ① 동일 사안일 것, ② 차별에 해당할 것, ③ 차별에 합리적 이유가 없을 것.

제2장 행정상 법률관계

제1절 행정주체

I. 의의

II. 공무원수탁사인

제2절 제재사유 및 제재효과의 승계

제2절 제재사유 및 제재효과의 승계:

1. 명문의 규정이 있는 경우

2. 명문의 규정 없는 경우: 대인적 처분- 승계 X
대물적 처분- 승계 O

제3절 특별권력관계

<★> 특별권력관계

의 : 일반권력관계와 달리 법률에 의한 기본권제한의 원칙이 존중될 필요 x

사법심사 대상 여부: O

특별권력관계 또한 법으로부터 자유로운 영역이 될 수 없으므로 사법심사의 대상이 됨 (명시적 판례 없는 듯)

<행정에 관한 기간의 계산> 박도원 27

1. 민법 준용

2. 침해적 처분의 경우

초일산입. 만료일이 공휴일 주말인 경우에도 그 날 만료.

제3장 사인의 공법행위

제1절 의의

제2절 사인의 공법행위로서의 신고

<★★★> 사인의 공법행위로서의 신고 18-1 18-3
의 : 사인이 행정청에 대하여 일정한 의사표시 or 일정한 관념 또는 사실을 통지함으로써 공법상의 효과를 발생하는 사인의 공법행위
유형 : 수리를 요하지 않는 신고(자기완결적 신고)는 그 자체가 행정기관에 도달한 때에 법적 효과가 발생하는 자기완결적 행위. 수리를 요하는 신고는 관계법상 행정청에 신고요건을 심사하여 수리 여부를 결정할 수 있는 권한이 부여
구별 기준 : 법률에 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있는 경우 수리하여야 효력 발생 (행기법 제34조) 나머지는 수리를 요하지 않는 신고(행정절차법 제40조)
*判) 주민등록전입신고는 수리를 요하는 신고 축산물판매업신고는 수리를 요하지 않는 신고
신고의 요건 : ① 신고서의 기재사항에 흠이 없고 ② 필요한 구비서류가 첨부되어 있으며, ③ 그 밖에 법령등에 규정된 형식상의 요건 에 적합할 경우, 신고서가 접수기관에 도달된 때에 신고 의무가 이행된 것으로 본다(행정절차법 제40조 제2항)
수리의 처분성: 수리를 요하지 않는 신고- 처분X 수리를 요하는 신고- 처분 O
수리의 기속행위성 : 신고가 관계 법령에 부합하는지 여부 및 구비서류 등이 갖추어져 있는지 여부 등을 심사하여 법 규정에 부합하는 이상 수리하여야. 判) 같은 법 규정에 정하지 아니한 사유로 신고수리 거부 할 수x
사인의 공법행위의 하자과 후속적 행정행위의 효력 : 판) 수리를 필요로 하는 신고의 경우 행정청이 그 신고를 수리하였다고 하더라도, 신고서 위조 등의 사유가 있어 신고행위 자체가 효력이 없다면 , 수리행위는 당연히 무효 . *判) 민법 제107조- 사인의 공법행위에는 준용x (ex사직의 의사표시)

지위승계신고의 수리
지위승계신고의 수리는 행정청의 구체적 사실에 대한 법집행으로서 공권력 행사 이고, 수리행위로 양도인의 법적 지위 소멸과 양수인의 법적 지위 창설의 구체적 효과가 발생하므로 국민의 권리의무에 직접적 영향을 미친다. 따라서 이 사건 지위승계신고의 수리 는 항고소송의 대상인 처분 이다.
<★★★> 일반적 건축신고의 수리거부의 처분성 중대한 공익상 필요
판 : 건축신고가 관계법령에서 정하는 명시적인 제한에 배치되지 않는 경우에도 중대한 공익상 필요 가 있는 경우 수리를 거부할 수 있다
<★★★> 개발행위허가의제 건축신고 [사시]
1st 신고의 구별기준 문 : 건축법상 건축신고의 성질 - 인허가의제 판 : 건축신고 는 건축법 제14조 제2항, 제11조 제5항 제3호의 인허가의제로 인해 건축법상 건축신고(①) 와 국토계획법상 개발행위허가(②) 의 성질을 아울러 갖게 되므로, ②를 받은 것으로 의제되는 건축신고가 ②의 요건을 갖추지 못한 경우 행정청은 수리를 거부할 수 있다. 문 : 인허가의제 효과를 수반하는 건축신고의 성질 - 수리 要 신고 판 : 일반적 건축신고와 달리 특사X, 행정청이 그 실체적 요건을 심사 한 후 수리하여야 하는 수리를 요하는 신고 로 보는 것이 옳다.

제2편 행정작용법

제1장 행정행위

제1절 재량권과 판단여지

<★★★> 기속행위와 재량행위의 구별

의의 : 기속행위- 법이 정한 요건이 충족되면 '반드시'

재량행위- 행정청에 독자적 판단권 부여

구별 기준 : 判) 일률적으로 규정지을 수는 없는 것이고, 당해 처분의 근거가 된 규정의 **형식**이나 **체제** 또는 **문언**에 따라 개별적으로 판단. 원칙적으로 수익적 행정처분은 재량행위에 속함. (형.체.문.목.특.성) 목적, 특성, 성질

*폐기물처리업허가, 매립목적 변경 승인, 마을버스운송사업면허, 형질변경행위 농지전용행위를 수반하는 건축허가, 도로점용 허가, 불확정 개념, 예외적 허가(승인), 특허 재량행위

<★★> 재량의 한계 [12회, 19-3, 19-1] 법.사.일.목.불

의의 : 행정청은 재량이 있는 처분을 할 때에는 관련 이익을 정당하게 형량하여야 하며, 그 재량권의 범위를 넘어서는 아니 된다(행기법 제21조). 행정청의 재량에 속하는 처분이라도 재량권의 한계를 넘거나 그 남용이 있는 때에는 법원은 이를 취소할 수 있다(행기법 제27조)

재량권의 일탈 남용의 기준 : 재량의 일탈, 재량의 남용, 재량의 흠결 또는 해태(형량을 전혀 x)

재량행위의 위법성 판단기준 : 법원은 독자적 결론을 도출함이 없이 재량일탈 남용만을 제한적으로 심사하며, 그 기준은 ①법령위반 ②사실오인 ③일반원칙 위반 ④수권목적 위반 ⑤재량권 불행사 또는 해태 여부이다.(법.사.일.목.불)

判) 감경사유를 전혀 고려하지 않았거나 감경사유에 해당하지 않는다고 오인- 재량권 일탈 남용

*Hint: 사소한 부주의, 경미한 위법, 처음 위반

☞ 재량권 불행사 or 비례원칙 위반

<★> 불확정개념과 판단의 여지 [13회] 재량의 문제

문: 상당한 이유, 공익, 필요한 경우, 공공질서

판 : 독자적인 개념으로 '판단의 여지'를 인정하지 않고 재량의 문제로 파악

제2절 행정행위의 종류

1. 법률행위적 행정행위

<★★> 허가 [14회, 24-2] 잠정적 금지, 자유를 회복

의의 : 질서유지 또는 위험의 예방을 위하여 일정한 행위를 법령에 따라 잠정적으로 금지시킨 후, 법정 요건을 충족하는 경우에 원래의 자유를 회복시켜주는 것 (대부분 기속행위)

예외적 승인(허가) : 그 전제가 되는 억제적 금지의 본질에 비추어 법문상 재량이 명백히 부여되어 있지 않더라도 재량행위로 보아야 하고 그 재량의 폭도 상대적으로 넓다.

*판) 개발제한구역 내 개발허가- 예외적 승인

<★★> 특허 [22-3, 18-3, 15-1, 12-2]

의의 : 특정인을 위하여 새로운 법률상 권리 등을 설정 (설권적 처분)

재량행위 여부 : 행정청이 공익의 실현을 위하여 합리적인 판단을 할 수 있도록 재량행위에 속하는 것이 일반적

*判) 공유수면매립면허, 체류자격 변경허가, 개인택시면허
☞ 특허, 재량

<★★> 인가 [14-1, 12-2, 12-2]

법률행위 보충. 법률효과 완성

기본행위 하자, 인가처분 취소무효 구할 법률상 이익x

의 : 제3자의 법률행위(기본행위)를 보충하여 법률효과를 완성시켜주는 행정행위

문 : 기본행위의 하자를 이유로 인가처분의 취소 또는 무효확인을 소구할 수 있는지 여부

判: 기본행위가 적법 유효하고 보충행위인 인가처분 자체에만 하자가 있다면 그 인가처분의 무효나 취소를 주장할 수 있지만, 인가처분에 하자가 없다면 기본행위에 하자가 있다 하더라도 기본행위의 무효를 내세워 바로 그에 대한 행정청의 인가처분의 취소 또는 무효확인을 구할 법률상의 이익이 없다.

<★★★> 조합설립인가 [18-2, 17-1, 16-1]

설권적 처분, 특허설. 조합설립결의 부분만- 확인의 이익x 이송

1. 추진위원회의 조합설립총회의 법적 성질

판: 주택재개발사업조합의 결의 x 주민총회 또는 토지 등
소유자 총회의 결의에 불과

☞ 사법상 합동행위. 민사소송의 대상.

2. 조합설립인가의 법적 성질 - 강학상 특허인지

문: 추진위원회의 조합설립 총회결의에 대한 관계행정청
의 조합설립인가처분이 강학상 특허인지 인가인지 그
법적 성질

학: ① 조합설립결의 효력을 보충·완성한다고 보는
인가설, ② 행정주체로서 포괄적 지위를 창설하는
설권적 행위로 보는 특허설, ③ 특허와 인가의 성격을
동시에 갖는 것으로 보는 특허·인가 복합체설

판: 조합설립인가는 행정주체의 지위를 부여하는 일종의
설권적 처분이라고 판시하여 특허설

검: 조합설립인가로 조합이 성립하면 조합은 도시정비법
상 사업시행주체가 되어 공법상 사단인 공공조합으로서
행정주체가 되므로 원칙적으로 특허설이 타당하다. 따라서
항고소송의 대상은 조합설립인가가 되고 피고는 인가
청이 된다.

3. 조합설립결의를 다투는 방법

가. 조합설립인가 전 쟁송방법

조합설립결의의 무효확인을 구하는 민사소송의 방법으로
다투어야 한다. 이 경우 조합설립결의의 효력을 다투는
확인이익이 인정된다.

나. 조합설립인가 후 쟁송방법

행정청을 상대로 조합설립 인가처분의 취소 또는 무효확
인을 구하는 항고소송의 방법으로 다투어야 한다.

조합설립결의는 처분의 사전절차로 처분에 흡수되므로
별도쟁송 대상이 아니므로, 조합설립결의의 부분만을 따
로 떼어내어 효력 유무를 다투는 확인의 소는 특사x 한
확인이익 X

다. 조합설립결의 무효확인의 소 제기 시 법원의 조치

① 관할법원으로 이송 후 법원의 허가를 얻어 조합설립인
가처분에 대한 항고소송으로 변경될 수 있음을 고려하여
보면, ② 주택재건축정비사업조합 설립 무효확인청구 부
분은 행정법원으로 이송함이 마땅하다.

4. 조합설립변경인가 총회결의를 다투는 방법

설립된 조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에
일정 정족수의 총회의결을 거쳐 시장·군수 등의 인가를
받아야 한다(도시정비법 제25조 제5항).

조합설립변경 인가 이전 조합설립변경에 대한 총회결의
의 효력 등을 다투는 소송은 공법상 당사자소송이 된다
(행정소송규칙 제19조 제3호 가목). 이때 피고는 권리주
체인 조합이 된다.

<★★★> 인허가의제 [24-3, 23-3, 22-1, 20-3, 20-3]

명시적 규정. 실체적 요건 충족. 협의가 된 사항만.

의제되는 인허가가 재량 → 주된 인허가도 재량.

별개로 의제된 인허가 거부처분 존재x

절차x실체o 협의, 독립쟁송x

1.의의: 주된 인허가를 받으면 법률로 정하는 바에 따라
그와 관련된 여러 관련 인허가를 받은 것으로 보는 것
(행기법 제24조 제1항)

2.요건

(1)절차적 요건: 법률에 인허가의제 시에도 관련 인허가
에 필요한 절차를 거친다는 명시적 규정이 있는 경우에
만 이를 거친다(행정기본법 제24조 제5항 단서)

(2)실체적 요건 : 인허가의제의 취지는 절차를 간소화하
여 국민의 권익을 보호하려는 것이지, 각각의 인허가 요
건에 관한 일체의 심사를 배제하려는 것으로 보기 어려
우므로 주된 인허가 요건뿐 아니라 관련 인허가 요건도
충족하여야 한다

3.효과

주된 인허가 행정청은 주된 인허가를 하기 전에 관련 인
허가에 관하여 미리 관련 인허가 행정청과 협의하여야
하고(행기법 제24조 제3항), 이에 따라 협의가 된 사항에
대해서만 주된 인허가를 받았을 때 관련 인허가를 받은
것으로 본다(행기법 제25조 제1항)

4.인허가의제가 인정되는 경우 재량행위 여부

판) 주된 인허가가 기속행위라도 의제되는 인허가가 재
량행위인 경우 주된 인허가는 재량행위.

5.독립쟁송 가능성

<★★★> 인허가의제 [24-3, 23-3, 22-1, 20-3, 20-3]

5. 독립쟁송 가능성

가. 부분 인허가의제의 의의

주된 인허가 행정청은 주된 인허가를 하기 전에 관련 인허가에 관하여 미리 관련 인허가 행정청과 협의하여야 하고(행정기본법 제24조 제3항), 이에 따라 협의를 한 사항에 대해서는 주된 인허가를 받았을 때 관련 인허가를 받은 것으로 본다(제25조 제1항).

부분 인허가의제란 주된 인허가로 의제되는 인허가 중 일부에 대하여만 의제되는 인허가 요건을 갖추어 협의가 완료된 경우에도 민원인의 요청이 있으면 주된 인허가를 할 수 있고 이 경우 협의를 완료된 일부 인허가만 의제되는 것을 말한다.

判) 모든 인허가의제 사항에 관하여 관계 행정기관의 장과 일괄하여 사전 협의를 거칠 것을 요건으로 하는 것은 아니고, 사업시행승인 후 관계 행정기관의 장과 협의를 거치면 그때 해당 인허가가 의제된다.

나. 부분 인허가의제의 경우

의제된 인허가는 통상적인 인허가와 동일한 효력을 가지므로, 적어도 '**부분 인허가의제**'가 허용되는 경우에는 그 효력을 제거하기 위한 법적 수단으로 의제된 인허가의 취소나 철회가 허용될 수 있고, 이러한 직권 취소·철회가 가능한 이상 그 의제된 인허가에 대한 쟁송취소 역시 허용된다.

관련 법령에서 의제된 인허가 사항의 변경 절차를 두고 있어 이후에 의제된 인허가 사항을 변경할 수 있다면, 사업계획에 대한 승인의 효력은 유지하면서 해당 의제된 인허가의 효력만을 소멸시킬 수 있다.

다. 주된 인허가의 거부처분의 경우

주된 인허가의 거부처분을 하면서 그 처분사유로 의제된 인허가의 거부 사유를 들고 있다고 하여 주된 인허가의 거부처분 외에 별개로 의제된 인허가의 거부처분이 존재하는 것이 아니므로, 그 주된 인허가의 거부처분에 관한 쟁송에서 의제된 인허가의 거부사유에 관하여 다룰 수 있는 것이지, 그 주된 인허가의 거부처분에 관한 쟁송과는 별개로 의제된 인허가의 거부처분에 관한 쟁송을 제기할 수는 없다.

기타 법률행위적 행정행위

하명: 행정청이 국민에게 작위 부작위 급부 수인 등의 의무를 명하는 행위.

면제: 법령에 따른 작위, 급부, 수인 등 의무를 해제시켜주는 행위

대리: 제3자가 하여야 할 일을 행정청이 대신

준법률행위적 행정행위

확인, 공증, 통지, 수리

<★★> 부관의 의의 및 종류 [1회, 5회, 24-3, 24-1]

문 : 이 사건 부관의 법적 성질이 문제된다.

의 : 처분에 재량이 있는 경우 부관을 붙일 수 있다(행기법 17조 1항)

조건 : 행정행위의 발생 또는 소멸- 장래의 불확실한 사실에 의존

부담 : 주된 내용에 부가하여 의무를 부과하는 부관.

<★★★> 부관의 가능성과 한계 행기 17조 2,3,4 항

1. 부관의 가능성

처분에 재량이 있는 경우 ○(행기 제17조 제1항), 처분의 재량이 없는 경우에는 법률에 근거가 있는 경우에(제2항)

2. 부관의 한계 (부. 비.)

① 해당 처분의 목적에 위배되지 아니할 것, ② 해당 처분과 실질적인 관련이 있을 것(부당결부금지), ③ 해당 처분의 목적을 달성하기 위하여 필요한 최소한의 범위일 것(비례의원칙, 행정기본법 제17조 제4항)

3. 부관의 사후부가

① 법률에 근거가 있는 경우, ② 당사자의 동의, ③ 사정이 변경되어 부관을 새로 붙이거나 변경하지 아니하면 처분의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우(행기 제17조 제3항) **법.동.사**

<★★> 부관의 독립쟁송가능성 [17-1, 24-1]

문 : 행정행위에 부가된 부관만을 독립하여 행정쟁송으로 다룰 수 있는지

학 : ① **부담은 그 자체로 특정한 의무를 명하는 처분**으로서의 성질을 가지므로 독립적으로 다룰 수 있다는 견해(부담만 가능) ② 소의 이익이 있는 한 취소소송의 대상이 될 수 있다는 견해(모든 부관) ③ **분리가능성**이 있는 부관만의 독립쟁송가능성을 인정하는 견해

판 : 원칙- 독립쟁송 x. 부담의 경우 **행정행위의 불가분적인 요소가 아니므로 부담에 한하여 독립쟁송가능성**을 인정

검 :

부관의 독립취소가가능성

判例는 부담에 한하여 독립쟁송가능성을 인정하는 입장에 따라, **부담만의 독립취소가 가능하다는 입장.**

제4절 행정행위의 효력

I. 공정력

처분은 취소 또는 철회하거나 기간의 경과 등으로 소멸되기 전까지는 **유효한 것으로 통용**(행기법 제15조)

> 상대방, 이해관계인 구속

<★★> 구성요건적 효력 [5회, 7회, 14회, 20-2]

무효x- 존중. 행소법 제11조 제1항.

하자가 단지 취소할 수 있는 정도, 취소되지 않는 한.

취소소송과 병합.

1. 의의

비록 행정행위가 하자가 있더라도 **무효가 아니라면** 모든 국가적 기관은 **행정행위의 존재 또는 효력을 존중**하여야 하는 구속력 (행기 제15조)

2. 선결문제

처분등의 효력 유무 또는 존재 여부가 민사소송의 선결문제로 되는 경우 수소법원은 이를 심리 판단 가능(행소 제11조 제1항)

3. 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 민사사건(국가배상소송)

학: ①부정설- 행소법 11조 1항에서 '효력 유무 또는 존재 여부'만을 규정(위법여부 언급x)

②긍정설- 행소법 11조 1항 > 예시적인 규정이므로 위법성에 대한 심사 가능

판: 긍정설

4. 행정행위의 존재 또는 무효 여부가 선결문제인 민사사건(부이반)

행소법 제11조 제1항.

判) 조세의 과오납. 과세처분의 **하자가 단지 취소할 수 있는 정도**에 불과한 경우- **취소되지 않는 한** 부당이득x (중대하고 명백해야)

☞ 먼저 취소소송 제기하여 승소 or **취소소송과 병합**

5. 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 형사사건

학: ①부정설- 행소법 11조 1항에서 '효력 유무 또는 존재 여부'만을 규정(위법여부 언급x)

②긍정설- 행소법 11조 1항 > 예시적인 규정이므로 위법성에 대한 심사 가능

판: 위반죄로 처벌 위해선 처분, 조치명령 적법해야.

당연무효 아니라도 위법한 처분인 한 위반죄x **긍정설**

6. 행정행위의 존재 또는 무효 여부가 선결문제인 형사사건

판) 취소사유에 불과한 운전면허- 취소되지 않는 한 유효.

∴ 무면허 운전 X

불가쟁력: 더 이상 다룰 수 x

행정행위의 상대방, 기타 관계인 - 구속 o

처분청 또는 국가기관- 구속x

제5절 행정행위의 하자

I. 하자의 판단시점: 행정처분시

<★★★> 행정행위의 무효와 취소 [6회, 모고 다수]

법규의 중요한 부분 위반, 중대한 것, 객관적으로 명백, 중대명백설

1. 의의

취소할 수 있는 행정행위는 권한 있는 기관이 취소하여야 효력 상실

2. 무효사유와 취소사유의 구별기준

구별실익: 무효확인소송(심판)or취소소송(심판).

제소기간, 전치주의, 사정판결...

학:①중대명백설: 하자의 내용 중대 + 외관상 명백

②명백성 보충요건설: 중대성은 항상 요구되나, 명백성은 법적안정성이나 제3자 보호 요청이 있는 경우에만 보충적.

③구체적 가치형량설:사안마다 구체적, 개별적 이익형량
判: **하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것으로서 객관적으로 명백한 것**이어야(중대명백설)

검: for법률적합성과 법적안정성의 조화, 중대명백설 타당

3. 개별 무효사유 및 취소사유

(1)주체에 관한 하자

내부위임- 위법무효

무효인 권한위임조례의 규정에 근거한 처분- 중대o명백x
>당연무효x

(2) 절차에 관한 하자

구 폐기물처리시설~ 입지선정위원회 전문가 포함시키지 않은 채 임의로 구성되어 의결 >>무효사유

학교환경위생정화위원회의 심의 누락 > 취소사유

(3) 형식에 관한 하자

행정절차법 제24조 위반(처분은 문서로) > 중대명백. 무효

(4)내용에 관한 하자

조례가 법률 등 상위법령에 위배된다는 사정- 특사없는 한 객관적으로 명백한 것 X, 취소사유

조합설립인가 처분- 토지면적의 3분의 2이상의 면적요건 > 당연무효

임용당시 공무원임용결격사유 > 임용은 당연무효

'토지 또는 건축물 소유자의 5분의 4이상'을

'토지소유자의 5분의 4이상 or 건축물 소유자의 5분의 4이상'으로 해석 >다의적 해석 여지 o, 명백x 당연무효x

※ 주의:

신고서 위조 등의 사유가 있어 신고행위 자체가 효력이 없다면. 그 수리행위는 유효한 대상이 없는 것으로서. 수리행위 자체에 **중대·명백한 하자가 있는지를 따질 것도 없이 당연히 무효**

<★★위헌결정의 소급효> [변 7, 22-1]

법적 안정성, 당사자의 신뢰보호 불가피, 소급효를 제한

1. 위헌결정의 효력

위헌결정의 효력은 그 결정이 있는 날부터 형벌에 관한 법률 등을 제외하고는 장래효로 규정되어 있다(헌법재판소법 제47조 제2항). 다만 실질적 정의를 고려하여 예외적 소급효를 인정한다.

2. 위헌결정의 소급효 인정 범위

① 위헌제청을 한 **당해사건**, ② 위헌결정 전 동일사유로 위헌심판제청 또는 제청 신청한 **동종사건**, ③ 따로 위헌제청신청을 아니하였지만 당해 법률조항이 재판의 전제가 되어 법원에 계속 중인 **병행사건**에 대하여 미치며, ④ 위헌결정 이후에 위와 같은 이유로 제소된 사건(일반사건).(당, 동, 병. 일).

☞ <대법원>은 ④ 일반 사건은 불가쟁력이 발생하지 않은 경우에는 소급효가 미칠 수 있으나, 쟁송제기기간을 경과하여 확정된 행정처분의 경우에는 소급효가 미치지 않아 취소소송을 통한 구제가 불가능하다고 한다.

3. 일반사건에 위헌결정의 소급효 인정 여부

判) 위헌결정 이후 제소된 일반사건에도 소급효를 인정하고 **법적 안정성의 유지**나 **당사자의 신뢰보호를 위하여 불가피한 경우** 위헌결정의 **소급효를 제한**할 수 있다.

<위헌법률에 근거한 처분의 효력> [22-1, 17-2]

1. 위헌결정의 소급효

2. 위헌법률에 근거한 처분의 효력

判例) 위헌법률에 근거한 처분은 처분에 근거가 되는 법률이 헌법에 위반된다는 점은 결과적으로 법률에 근거 없이 처분이 행하여진 것과 마찬가지이므로 **하자가 중대하나 법률의 위헌 여부는 위헌결정이 있기 전에는 객관적으로 명백하지 않으므로 취소사유에 해당한다(중대명백설)**.

<★★> 위헌 결정된 법률에 근거한 행정행위의 집행력

<위헌결정 후 위헌법률에 근거한 처분의 집행력>

1. 위헌결정의 소급효

2. 위헌법률에 근거한 처분의 효력

당연무효(위헌결정의 효력에 위배- 중대명백)

3. 위헌법률에 근거한 처분의 집행력 인정 여부

문제점

위헌결정의 기속력과 관련하여 법률의 위헌결정 이후 위헌법률에 근거한 행정처분의 집행력이 인정되는지 문제된다.

판: 위헌 결정 이후에 **새로운 체납처분**에 착수하거나 이를 속행하는 것은 더 이상 허용되지 않고, 나아가 이러한 위헌결정의 효력에 위배하여 이루어진 체납처분은 그 사유만으로 **하자가 중대하고 객관적으로 명백하여 당연무효**라고 판시하여 **집행력을 부정**하는 입장이다.

☞ 행정처분에 확정력이 발생한 후 위헌 결정이 되었다고 후속 절차는 위헌결정의 기속력으로 인해 진행할 수 없다.

<★★> 하자 있는 행정행위의 치유 [3회, 20-2]

사후 흠결 보완, 구체적사정에 따라 합목적적으로 인정, 행정쟁송 제기 이전

1. 의의

행정행위의 치유란 행정행위가 성립 당시에는 위법한 것이었지만 **사후에 흠결이 보완**되는 경우, 성립 당시의 **하자에**도 불구하고 **적법한 행위로 유지**시키는 것을 말한다.

2. 허용여부

하자 있는 행정행위의 치유는 행정행위의 성질이나 법치주의의 관점에서 볼 때 원칙적으로 허용될 수 없는 것이고, 예외적으로 행정행위의 무용한 반복을 피하고 당사자의 법적 안정성을 위해 이를 허용하는 때에도 국민의 권리나 이익을 침해하지 않는 범위에서 **구체적 사정에 따라 합목적적으로 인정**하여야 할 것이다.

3. 한계

당연무효인 처분은 하자 **치유x**

처분의 하자의 치유를 허용하려면 늦어도 처분에 대한 불복여부의 결정 및 불복신청에 편의를 줄 수 있는 상당한 기간내에 하여야 한다고 할 것이므로, **행정심판 또는 행정소송 제기 이전**까지만 인정된다(행정쟁송제기전설).

<★★★> 행정행위의 하자의 승계 [변9, 6, 21-1, 20-1]

연,취,불,없. 하자승계론.

수인한도 넘는 가혹함. 예측가능성

1. 논의의 전제조건

① 둘 이상의 행정행위가 **연속적으로** 행해지고 ② 선행행위에 무효가 아닌 **취소**사유가 있지만 ③ **불가쟁력**이 발생한 경우 ④ **하자가 없는 후행행위**를 다룰 수 있는지(연취불없)

선행처분과 후행처분이 서로 독립하여 별개의 법률효과를 목적으로 하는 때에도 **선행처분이 당연무효**인 경우 선행처분의 하자를 이유로 후행처분의 효력을 다룰 수 있기 때문이다.

2. 학설

① 연속된 행정행위가 **하나의 효과를 목적으로 하거나 동일한 목적을 달성하는 경우**에는 선행행위의 위법을 이유로 후행행위의 위법을 주장할 수 있다는 **하자승계론**,

② 선행행위가 후행행위에 대하여 **구속력이 미치는 범위** 내에서는 후행행위의 단계에서 선행행위의 효과와 다른 주장을 할 수 없게 된다는 **구속력론**

3. 판례

판례는 **기본적으로 하자승계론**의 입장에 따라, 연속된 행정행위가 **하나의 효과를 목적으로 하거나 동일한 목적을 달성**하는 경우에만 하자의 승계를 인정(하자승계론)

다만, 선행처분과 후행처분이 **서로 독립하여 별개의 효과를 목적으로 하는 경우**에도 선행처분의 불가쟁력이나 구속력이 그로 인하여 불이익을 입게 되는 자에게 **수인한도를 넘는 가혹함을 가져오며, 그 결과가 당사자에게 예측가능한 것이 아닌 경우** 하자의 승계를 인정(수인한도론)

하자의 승계 여부	사례
O	개별공시지가 & 조세부과처분 표준공시지가 & 수용재결 계고처분 & 대집행비용납부명령
X	표준공시지가 & 개별공시지가 표준공시지가 & 조세부과처분 직위해제처분 & 면적처분 사업인정처분 & 수용재결 주택재건축 사업시행계획 & 관리처분계획

제6절 행정행위의 취소 및 철회

<★★> 행정행위의 취소 [12회, 23-3]

공익과 비교형량.

수익적- 적극설, 침익적- 소극설

1. 의의

행정청은 위법 또는 **부당한** 처분의 전부나 일부를 소급하여 취소할 수 있다. 다만 당사자의 신뢰를 보호할 가치가 있는 등 정당한 사유가 있는 경우에는 장래를 향하여 취소할 수 있다(행정기본법 제18조 제1항)

2. 한계

행정청은 당사자에게 **권리나 이익을 부여하는 처분**을 취소하려는 경우에는 취소로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 취소로 달성되는 **공익과 비교형량**하여야 한다. 다만, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 처분을 받은 경우, 당사자가 처분의 위법성을 알고 있었거나 중대한 과실로 알지 못한 경우에는 그러하지 아니하다(행정기본법 제18조 제2항)

3. '무효사유 있는 취소'의 취소

별도로 취소할 필요없이 원행정행위 존속

4. '취소사유 있는 취소'의 취소

학: ① 원행정행위는 **취소에 의하여 그 효력이 확정적으로 소멸되기 때문에** 취소의 취소에 의하여 **원행정행위를 소생시킬 수 없다**는 소극설

② **취소도 독립된 행정행위**이므로 취소행위를 다시 취소하여 **원행정행위를 소생시킬 수 있다**는 적극설

판: 원행정행위가 **수익적 행정행위- 적극설**

침익적 행정행위- 소극설

<★★> 행정행위의 철회 [변5, 24-3, 20-2, 13-2] 행기 19조

1. 의의

행정행위의 철회는 **하자 없이 성립한** 행정행위에 대하여 그 효력을 존속시킬 수 없는 새로운 사정이 발생하였음을 이유로 장래에 향하여 그의 효력을 소멸시키는 행정행위를 말한다.

2. 철회사유

행정청은 적법한 처분이 ① 법률에서 정한 철회사유에 해당하게 된 경우, ② 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우, ③ 중대한 공익을 위하여 필요한 경우에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다(행정기본법 제19조 제1항).

3. 철회권의 제한

행정청은 처분을 철회하려는 경우에는 철회로 인하여 당사자가 입게 될 불이익을 철회로 달성되는 **공익과 비교형량**하여야 한다(행정기본법 제19조 제2항)

☞ 취소라고 써있어도 철회인지 의심할 것.

<처분에 대한 이의신청>

1. 의의

행정청의 처분에 이의가 있는 당사자는 처분을 받은 날부터 **30일 이내**에 해당행정청에 이의신청을 할 수 있다 (**행정기본법 제36조 제1항**).

2. 효과

이의신청을 한 경우에도 그 **이의신청과 관계없이** 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다(**행정기본법 제36조 제3항**).

이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 **결과를 통지받은 날**(통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 통지기간이 만료되는 날의 다음날)부터 **90일 이내**에 **행정심판 또는 행정소송**을 제기할 수 있다.

제2장 행정입법

제1절 법규명령

기본개념 (숙지되면 삭제할 것)

법령(법률 + 법규명령)	
협회의 법규명령	광의의 법규명령
대통령령(시행령) 총리령, 부령(시행규칙)	법령보충적 행정규칙 (=법규명령) 조례 = 광의의 행정입법

*고시 등= 행정규칙(훈령, 지침, 예규, 통첩)

법규명령: 대외적 구속력=법규성=재판규범성 o

위임명령(대통령령, 총리령, 부령)-법규명령의 성격

법령보충적 행정규칙

: 법규명령의 효력을 갖는 행정규칙(고시, 훈령 등)

상위법령과 결합, 법규명령의 일부가 됨.

제2절 행정규칙

위임명령의 제정범위와 한계

위임명령은 상위법령으로부터 구체적 범위를 정하여 위임받은 사항에 대해서만 정할 수 있다.

①**법률에 위반되어서는 아니 되며**, ②**국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 경우와 그 밖에 국민생활에 중요한 영향을 미치는 경우에는 법률에 근거하여야 한다**(**행정기본법 8조**)

判例 : 위임명령이 법령에 근거를 둔 것이더라도 규정 내용이 법령의 **위임 범위를 벗어난 것**일 경우에는 **법규명령으로서의 대외적 구속력을 인정할 여지는 없다.**

*기재례:

‘이 사건 지침은 행정규칙에 불과하여 대외적 구속력이 없다’_

‘이 사건 고시 조항은 ~ 위임의 한계를 벗어났다.’

<★★> 법규명령에 대한 사법적 통제[17-2, 15-3]

집행행위의 매개 없이

1. 일반법원에 의한 통제

가. 구체적 규범통제

명령 규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다(**헌법 제107조 제2항**). 따라서 법규명령의 위헌 위법성은 **구체적 사건에서 재판의 전제가 된 경우에만 선결문제**로서 다루어질 수 있다.

나. 법규명령에 대한 항고소송

일반적 추상적 성격을 가지는 법규명령 또는 행정규칙은 처분성 X

but 법규명령 또는 행정규칙이 다른 **집행행위의 매개 없이** 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법률관계를 규율하는 성격을 가질 때에는 예외적으로 항고소송의 대상이 되는 **행정처분**에 해당한다.

2. 헌법재판소에 의한 통제

判例: 규칙이 **별도의 집행행위를 기다리지 않고 직접 기본권을 침해하는 것**일 때에는 모두 **헌법소원심판의 대상**이 될 수 있다.

☞ 기초내용

행정규칙이 대외적 구속력을 갖지 않는 경우 원칙적으로 법원의 규범통제 대상 x

법령보충적 행정규칙인 경우 규범통제 대상이고,

처분적 고시는 항고소송의 대상 o

****행정규칙은 헌법소원의 대상인 공권력 행사가 아니나, 행정규칙이 법령보충적 행정규칙인 경우와 자기구속원칙을 매개하여 대외적 구속력이 인정되는 경우 헌법소원의 대상 o**

<행정규칙>

상급행정기관이 하급행정기관에 법률의 수권 없이 자신의 권한 내에서 내리는 일반적 추상적 규율

훈령: 상급행정기관이 하급행정기관에 대하여 장기간에 걸쳐 그 권한 행사를 일반적으로 지시하기 위하여 발하는 명령
예규: 행정사무의 통일을 기하기 위하여 반복적 행정사무의 처리기준을 제시하는 법규문서 외의 문서

고시: 법령에서 위임하는 바에 따라 법령 내용을 보충하기 위하여 법규적 사항을 정하거나, 법령에서 정하는 바에 따라 **일정한 사항을 일반에게 알리기 위한 문서**

<★★> 행정규칙의 효력 및 통제 [변3, 13]

1. 효력

행정규칙은 **대외적 구속력** x

∴ **행정처분**이 행정규칙에 따라 이루어졌더라도 해당 처분이 **적법한지**는 **법령의 규정**과 **비례** **평등원칙**과 같은 **법의 일반원칙**에 적합한지 여부에 따라 판단(判例)

2. 통제

법원은 행정규칙에 구속되지 않는다. 그러나 그 기준의 설정이나 변경이 객관적으로 합리적이 아니라거나 타당하지 않다고 보이지 아니하는 이상 행정청의 의사는 가능한 한 존중되어야 한다.(判例)

제3절 입법형식과 규일방식의 불일치 (예외)

<★★> 법규명령 형식의 행정규칙(제재적 처분기준)

[변3, 4, 18-2, 16-2] **대통령령-법규명령. 부령-행정규칙**

문: 법규명령으로 볼지? 행정규칙으로? (대외적구속력)

학:

- ①법규명령설: 내용에 관계없이 당해 규범의 형식을 중시
- ②행정규칙설: 규범의 실질적 내용을 중시

판: **대통령령(시행령)**으로 정한 행정처분의 기준은 **법규명령**으로 보면서도 일정한 금액으로 정한 처분기준의 경우 **최고한도액**을 정한 것이라고 보았고, **부령(시행규칙)**으로 정한 행정처분의 기준은 **행정규칙**으로 봄

<★★★> 행정규칙 형식의 법규명령 [4, 8, 11, 모고 다수] **위임한계를 벗어나지 아니하는 한**

1.학설

- ①**법규명령설**: 법령의 구체적·개별적 위임에 따라 법규를 보충하는 기능과 대외적 효력을 가지므로 법규명령
- ②**행정규칙설**: 행정입법은 국회입법의 원칙에 대한 예외이므로 **헌법에 근거가 있어야**
- ③**위헌무효설**: 헌법적 근거가 없는 위임입법이므로 **위헌**이어서 **무효**

2. 판례

행정규칙이상위법령의 **위임한계를 벗어나지 아니하는 한** 상위법령과 결합하여 대외적인 구속력이 있는 **법규명령으로서의 효력**을 갖게 된다.

<★★★> 행정계획 [변14, 22-2, 21-3 모고다수]

권리를 개별적 구체적으로 규제

1.의의

행정에 관한 전문적·기술적 판단을 기초로 하여 특정한 행정목표를 달성하기 위하여 서로 관련되는 행정수단을 종합·조정함으로써 **장래의 일정한 시점에 있어서 일정한 질서를 실현**하기 위한 활동기준으로 설정된 것(判)

2. 행정계획의 법적성질(처분성)

행정입법설, 행정행위설, 독자성설 등이 대립하나, 判例는 특정개인의 **권리 내지 법률상의 이익을 개별적이고 구체적으로 규제**하는 효과를 가져오게 하는 행정계획은 **처분**으로 보고, 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 것이 아닌 행정계획은 처분으로 보지 않는다.(判)

3. 행정계획의 적법요건

행정계획 수립, 변경, 폐지- 여러 이익을 정당하게 형량 (행정절차법 제40조의4)

<★★★> 계획재량과 형량명령

공익과 사익 정당한 형량

1. 계획재량의 의의

계획재량이란 계획법규에 근거하여 구체적인 계획을 책정할 때 계획행정청이 가지는 재량을 말한다.

2. 형량명령의 의의

형량명령은 **계획재량을 제한**하는 이론으로서, **행정계획을 수립할 때 관련 공익 또는 사익 사이에 정당한 형량이 행해져야 한다**는 원칙을 말한다. 이러한 법리는 행정계획 결정을 할 것인지를 결정하는 경우뿐만 아니라, 기존의 계획설정을 변경, 폐지할 것인지 여부를 결정할 때에도 마찬가지로 적용된다.(判)

3. 형량명령의 내용

형량을 전혀 하지 않은 경우(**형량의 해태**), 형량의 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 빠뜨리고 형량을 행한 경우(**형량의 흠결**), 이익형량을 행하기는 하였으나 그것이 객관성, 비례성을 결한 경우(**오형량**)에 형량의 하자가 발생하여 법원의 심사대상이 된다.

☞ 관련쟁점: '계획변경 신청권 유무',
' 행정법의 일반원칙 > 신뢰보호의 원칙'

제3절 공법상 계약

<★★> 공법상 계약 [변14, 22-2, 21-3 모고다수]
1.의의 행정주체 상호간 또는 행정주체와 사인 간 공법적 효력 발생을 내용으로 하는 계약
2. 처분과의 구별 처분은 행정청이 우월적 지위에서 일방적으로 행사하지만, 공법상 계약은 양 당사자의 합의 에 의하여 성립.
행정청이 자신과 상대방 사이의 법률관계를 일방적인 의사표시로 종료시켰다고 하더라도 곧바로 행정처분 단정x 관계 법령이 상대방의 법률관계에 관하여 구체적으로 어떻게 규정하고 있는지에 따라 개별적으로 판단(判例)
*산업단지입주변경계약 취소- 산업단지관리공단이 우월적 지위 에서~ 행정처분에 해당

제4절 행정상 사실행위

행정상 사실행위
행정기관의 행위 중 사실상의 효과만을 발생시키는 일체의 행위형식. 공권력의 행사로서 일방적으로 강제하는 성질을 갖는 권력적 사실행위 와 공권력의 행사로서의 성질을 갖지 않는 비권력적 사실행위로 구분.

제5절 행정지도

<★> 행정지도 [13-1]	행정절차법 제49조
행정기관이 그 소관 사무의 범위에서 일정한 행정목적을 실현하기 위하여 특정인에게 일정한 행위를 하거나 하지 아니하도록 지도, 권고, 조언 등을 하는 행정작용(행정절차법 2조 3호)	
행정지도를 하는 자는 그 상대방에게 그 행정지도의 취지 및 내용과 신분을 밝혀야 한다(행정절차법 제49조 제1항). 행정지도가 말로 이루어지는 경우에 상대방이 제1항의 사항을 적은 서면의 교부를 요구하면 그 행정지도를 하는 자는 직무수행에 특별한 지장이 없으면 이를 교부하여야 한다(행정절차법 제49조 제2항)	
행정지도는 그 목적 달성에 필요한 최소한도에 그쳐야 하며, 행정지도의 상대방의 의사에 반하여 부당하게 강요하여서는 아니 된다(행정절차법 제48조 제1항) 判) 원칙적으로 처분성 x	

제3편 행정절차·행정정보

행정절차법 사례 목차
1. 행정절차법 적용 여부 2. 처분의 방식: 서면 3. 사전통지(거부처분의 사전통지 불가능) 4. 의견청취 5. 처분의 이유제시 6. 절차적하자의 독립적 취소사유성
<★★★> 행정절차법의 적용범위 [변10, 21-3, 21-2, 20-3 등]
문 : 행정절차법의 적용범위
조 : 행정절차법 제3조 ※ 제2조 제1항 제9호'공무원 인사 관계 법령 ~' 判) 성질상 행정절차를 거치기 곤란하거나 불필요하다고 인정되는 처분이나 행정절차에 준하는 절차를 거치도록 하고 있는 처분의 경우 적용 배제
문 : 외국국적 재외동포에 대한 사증발급거부의 경우 적용
판 : 출입국관리법령에 사증발급 거부처분서 작성에 관한 규정이 없는 바 행정절차법 제24조에 정한 절차를 따르지 않고 행정절차에 준하는 절차로 대체할 수 없다. 따라서 사증발급 거부처분은 적용배제 사항인 외국인의 출입국에 관한 사항에 해당하지 않는다.
문 : 공무원의 직권면직(or 퇴학)의 경우 절차법 적용여부 적용
판 : 행정의 공정성, 투명성, 신뢰성 확보 및 국민의 권익 보호 를 목적으로 하는 행정절차법 규정에 비추어 성질상 행정절차를 거치기 곤란하거나 불필요 하다고 인정되는 처분이나 행정절차에 준하는 절차 를 거치도록 하는 경우에만 행정절차법의 적용이 배제 되는 것으로 보아야 한다. -> 직권면직, 퇴학처분 = 적용
문 : 군인사법령상 긴급선발취소처분의 경우 적용
판 : 군인사법령은 행정절차에 준하는 절차규정이 없고, 처분의 성질상 행정절차를 거치기 곤란하거나 불필요하다고 인정되는 처분이 아니므로 행정절차법의 적용이 배제되지 않는다.
문 : 공무원의 직위해제처분의 경우 적용 배제
판 : 국가공무원법상 직위해제처분은 소청심사를 통한 충분한 소명기회가 보장되어 있고 대기명령자 직권면직시 징계위원회의 동의 등 절차적 보장이 강화되어 있으므로 적용배제
문 : 사관생도 퇴학 처분의 경우 적용
판 : 교육·훈련의 목적을 직접 달성하기 위하여 행하는 사항을 말하는 것으로 보아, 생도에 대한 퇴학처분과 같이 신분을 박탈하는 징계처분은 해당 X

행정절차법상 당사자 등

직접 당사자 + 이해관계인 (행정절차법 제2조 제4호)

당사자들은 배우자 등 대리인 선임가능,

당사자 등이 법인인 경우 변호사 선임(행정절차법 12조 제1항)

<★> 처분의 신청 [17-3]

처분을 구하는 신청은 문서로(행정절차법 제17조 제1항).

구비서류의 미비 등 흠이 있는 경우 신청인에게 **보완을 요구하여야**(행정절차법 제17조 제5항).

보완 또는 보정의 대상: 형식적, 절차적 요건 O

실질적인 요건 X (判例)

<★★> 처분의 방식 [23-1, 21-2]

행정청이 처분을 할 때에는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 **문서로 하여야**(행정절차법 제24조 제1항)

判) **외국인의 사증발급 신청에 대한 거부처분**: 당사자에게 의무를 부과하거나 적극적으로 권익을 제한하는 처분 X

☞ 사전통지, 의견제출 기회 부여 대상 X

그러나 처분서 작성 교부 要

제2절 행정절차법의 주요 절차

<★★★> 처분의 사전통지 [변 2, 11, 23-1, 18-3, 17-3]

소극설

1. 의의

행정청은 **당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분**을 하는 경우에는 미리 당사자에게 통지하여야 한다. (행정절차법 제21조 제1항)

2. 사전통지의 생략

행정절차법 제21조 제4항 or 제21조 제5항

(긴급, 명백히 증명완, 불현곤)

判)기소유에 처분- '전제되는 사실이 객관적으로 증명'되어 **의견청취 불필요한 경우 X**

3. 거부처분의 사전통지 **거부처분- 사전통지 X**

문 : 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 미리 당사자들에게 통지하여야하는바(행정절차법 제21조 제1항), 여기에서 **거부처분도** 불이익처분에 포함된다고 해석하여 **사전통지의 대상이 되는지** 문제된다.

학 : ①거부처분의 발령만으로는 당사자의 신청이 받아들여지지 않을 것을 의미할 뿐, **당사자의 권익이 실질적으로 제한되는 효과가 나타난 것은 아니**라는 소극설

②신청에 대한 거부처분은 당사자의 권익을 제한하는 처분에 해당한다는 적극설

판 : 신청에 따른 처분이 이루어지지 아니한 경우에는 아직 당사자에게 권익이 부과되지 아니하였으므로 직접 당사자의 권익을 제한하는 것은 아니라면서, **소극설**

<★★★> 의견청취 [변 3, 22-1, 20-3, 15-2, 14-3, 13-2]

判) 징계심의대상자에게 **변호사를 통한 방어권의 행사를 보장**하는 것이 필요하고, 변호사가 징계위원회에 출석하여 필요한 의견을 진술하는 것은 **방어권 행사의 본질적 내용**이므로, 행정청은 **특사 없이 거부 X**

1. 청문

행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자들의 의견을 직접(서면x) 듣고 증거를 조사하는 절차(행정절차법 제2조 제5호)

다른 법령에서 청문을 하도록 규정하고 있는 경우 등(행정절차법 제22조 제1항) > 청문 하여야

判) 방문하여 '처분을 연기해달라'는 내용의 서류 제출- 청문X

2. 공청회(행정절차법 제2조 제6호)

다른 법령에서 공청회를 개최하도록 규정하고 있는 경우 등(행정절차법 제22조 제2항)

3. 의견제출의 기회(행정부 제2조 제7호)

행정청이 당사자에게 **의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분**을 하면서 **청문이나 공청회를 하지 않는 경우**에는 당사자들에게 의견제출의 기회를 주어야 한다(행정절차법 제22조 제3항)

4. 의견청취의 예외사항에 해당하는 경우

<행정절차법 제22조 제4항, 제21조 제4항>의 사유

<★★> 처분의 이유제시

가. 의의

처분을 할 때는 그 근거와 이유 제시(행절 제23조 1항)
사전통지 및 의견청취와 달리, 모든 처분에 적용

나. 이유제시의 예외

(1)신청 내용을 **모두 그대로 인정하는 처분**인 경우
이유제시 X(23조 제1항 1호)

(2) 제23조 제1항 제2호, 3호의 경우 이유제시x
(단, **당사자가 요청하는 경우** 이유제시 o, 23조 2항)

☞ 1호는 해당안됨 주의!

다. 이유제시의 정도 (법적근거, 사실적 근거)

일반적으로 **당사자가 그 근거를 알 수 있을 정도로 상당한 이유를 제시한 경우**에는 당해 처분의 근거 및 이유를 구체적 조항 및 내용까지 명시하지 않았더라도 위법 X

이때, '이유를 제시한 경우'는 처분 당시 당사자가 어떠한 근거와 이유를 처분이 이루어진 것인지 충분히 알 수 있어서 **그에 불복하여 행정구제절차로 나아가는 데 별다른 지장이 없었다고 인정되는 경우**를 뜻한다.

처분기준의 설정·공표
1. 의의 행정청은 필요한 처분기준을 해당 처분의 성질에 비추어 되도록 구체적으로 정하여 공표하여야.(+변경) 절20조3항
2. 처분기준을 설정 공표하지 아니하고 처분 한 경우 20조 1항의 처분기준 사전공표 의무를 위반 , 그러한 사정만으로 곧바로 해당 처분에 취소사유에 이를 정도의 흠이 존재한다고 볼 수는 없다 . 상위법령 위반, 일반원칙 위반, 객관적 합리성 없음 등의 사정이 있어야 위법
송달 (행정절차법 제14조)
14조 꼭 검토!

제3절 절차상 하자의 독자성 여부

<★★> 절차상 하자의 독자성 여부 [22-3, 20-2] 소적,절, 절충설, 원칙 취소, 방어권 실질 지장x 특사-취소 x 문: 절차를 준수하였더라도 동일한 결론에 도달할 수 밖에 없는 경우, 절차적 하자가 그 자체로 독립적인 취소사유가 되는지 문제된다.
학: ①처분에 실체적 하자가 존재하지 않는다면 절차상 하자의 존재만으로 처분을 취소할 수 없다는 소극설 , ②행정행위에 절차적 하자가 존재하는 경우에는 실체적 하자가 존재하지 않는 경우에도 당해 행정행위의 무효 또는 취소사유가 된다는 적극설 , ③절차의 위반이 실체적 결정에 영향을 미쳐 당사자의 실체적 권리를 침해하였다면 독자적인 취소사유가 될 수 있다는 절충설 .
판: 행정청이 처분절차에서 관계법령의 절차 규정을 위반하여 절차적 정당성이 상실된 경우에는 해당 처분은 위법하고 원칙적으로 취소하여야 한다. 다만, 처분상 대방이나 관계인의 의견진술권이나 방어권 행사에 실질적으로 지장이 초래되었다고 볼 수 없는 특별한 사정이 있는 경우 에는, 절차 규정 위반으로 인하여 처분절차의 절차적 상당성이 상실되었다고 볼 수 없으므로 해당 처분을 취소할 것은 아니다 라고 하여 절충설 의 입장이다.

제2장 행정조사

제1절 의의

<★★> 행정조사 [변7, 11, 19-1, 12-3] 1. 의의 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사, 문서열람, 시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고요구, 자료제출요구, 출석, 진술요구를 행하는 활동을 말한다 (행정조사기본법 제2조 제1호) *법전에 없음*
2. 행정조사의 절차 행정조사를 실시하고자 하는 행정기관의 장은 출석요구서 등을 조사개시 7일 전까지 조사대상자에게 서면으로 통지하여야 한다.(행정조사기본법 제17조 제1항)
3. 위법한 행정조사에 기한 행정행위의 효력 학: 위법성이 행정행위에 승계된다고 보는 적극설 행정조사와 행정행위는 별개이므로 승계x 소극설 판: 위법사유가 있는 세무조사에 의하여 수집된 과세자료를 기초로 한 과세처분 역시 위법하다(적극설) ☞하자의 승계와 혼동 주의!(행정조사는 처분 아님)

제3장 정보공개

<★★★> 정보공개 [23-1 22-3 19-2 17-3 16-2 13-2]

1. 정보공개청구의 당사자

(1) 정보공개 청구권자: **모든국민**(**공공기관의 정보공개에 관한 법률 제5조 제1항**)

외국인은 1) 국내에 일정한 주소를 두고 거주하거나 학술 연구를 위하여 일시적으로 체류하는 사람, 2) 국내에 사무소를 두고 있는 법인 또는 단체에 해당하는 자.(5조2항)

(2) 정보공개 의무기관

1) 국가기관, 2) 지방자치단체, 3) 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관, 4) 지방공사 및 지방공단, 5) 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관. 5) **그 밖에 대통령령으로 정하는 기관**(정보공개법 제2조 제3호)

2. 공개청구의 대상 및 방법

공공기관이 보유 관리하는 정보. 전자매체를 비롯한 모든 형태의 매체 등에 기록된 사항(정보공개법 제2조 제1호). 청구인에게는 **특정한 공개방법**을 지정하여 정보공개를 청구할 수 있는 법령상 신청권이 있다(判例)

3. 정보공개법의 기본원칙

(1) 정보공개 원칙(정보공개법 제3조)

判) 이미 다른 사람에게 공개하여 널리 알려져 있다거나 인터넷검색 등으로 쉽게 알 수 있다는 사정만으로 소의 이익이 없다거나 **비공개결정이 정당화 될 수 없다.**

(2) **비공개사유** (정보공개법 제9조 제1항)

1) 다른 법률에 의해 비밀or비공개 사항으로 규정된 정보
判) 국세기본법상 과세정보

2) 공개될 경우 국민의 생명 신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보

3) 진행 중인 재판에 관련된 정보와 범죄에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하거나 형사피고인의 공정한 재판을 받을 권리를 침해한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

4) 의사결정 과정 또는 내부 검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구 개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보

☞ **비교 교량하여 구체적 사안에 따라 판단(判)**

* 判) 의사결정과정에 제공된 회의관련자료나 의사결정과정에서 기록된 회의록 등은 의사결정과정에 있는 사항에 준하는 사항으로서 **비공개대상정보에 포함될 수 있다**

(3) **정보공개청구의 권리남용**

判) 부당한 이득 목적, 오로지 공공기관의 담당공무원을 괴롭힐 목적으로 정보공개청구 하는 등 **권리남용이 명백한 경우** 정보공개청구권 행사 허용x

4. 부분 공개(정보공개법 제14조)

if 비공개 부분과 공개가능 부분 혼합 + 분리가능,

비공개사유에 해당하는 부분을 제외하고 공개하여야

<★> 정보공개절차 [16-2]

1. 제3자의 의견청취

공개청구된 공개 대상 정보가 제3자와 관련, 제3자에게 지체없이 통지. 필요한 경우 의견청취(제11조 제3항) 통지받은 제3자는 3일 이내에 공개거부 요청 可(21조1항) 비공개 요청에도 불구하고 공개 결정을 할 때에는 공개 결정 이유와 공개 실시일을 지체없이 문서로 통지. 제3자는 이의제기(7일 이내) 및 행정심판or행정소송 가능(정보공개법 제21조 제2항)

2. 반복청구 등의 처리

1) 정보공개 여부에 대한 결정 통지를 받은 자가 **정당한 이유 없이 해당 정보의 공개를 다시 청구하는 경우**, 2) 정보공개 청구가 **민원으로 처리되었으나 다시 같은 청구를 하는 경우에는 해당 청구를 종결 처리 가능**

제4편 행정의 실효성 확보

제1장 행정상 강제

제1절 행정대집행

<★★> 행정대집행 [22-3, 20-2] **대불,다이,불공**

1. 의의(행정대집행법 제2조)

대체적 작위의무의 불이행에 대하여, 당해 행정청은 스스로 행위를 하거나 제3자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다.

2. 요건(대불.다이.불공.)

① 공법상 **대체적 작위의무** 불이행, ② 다른 수단으로 이행확보 곤란, ③ 그 불이행을 방치함이 심히 공익을 해하는 것을 요건으로 한다(행정대집행법 제2조)

비대체적 작위의무(퇴거의무 및 명도의무), 부작위의무 및 수인의무는 대집행의 대상 X

判) 도시공원시설 점유자의 **퇴거 및 명도의무**는 대체적 작위의무x라서 **대집행의 대상 X**

3. 절차

상당한 기한을 정하여 그 기한까지 이행되지 아니할 때에는 대집행한다는 뜻을 미리 계고하여야(행정대집행법 제3조 제1항), 예외: 비상시, 위험 절박 계고x(3조 3항)

4. 결합계고의 적법성

문: 한 장의 문서로 철거명령과 대집행 계고를 한 경우 이행기간이 철거에 필요한 기간이면서 동시에 계고에 필요한 기간이 되므로 그 적법성이 문제된다.

판: 한 장의 문서로 철거명령과 대집행 계고를 한 경우 하명처분과 계고처분은 **독립하여 있고** 자진철거에 필요한 상당한 기간에는 계고에 필요한 상당한 기간이 포함되어 **각각 그 요건이 충족된 것으로 본다.**

제2절 이행강제금의 부과

<★★> 이행강제금의 부과 [13-2] **비대체적, 대체적 0**

1. 의의(행정기본법 제30조 제1항 제2호)
의무자가 행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 적절한 이행기간을 부여, 그 기한까지 이행하지 아니하면 금전급부 의무를 부과하는 것.
이행강제금은 부작위의무나 비대체적 작위의무에 대한 강제집행수단으로 이해되어 왔으나, 이행강제금은 대체적 작위의무의 위반에 대하여도 부과할 수 있다.
判) 이행강제금 납부의무는 상속인 기타의 사람에게 승계될 수 없는 일신전속적인 성질의 것

2. 부과 징수 절차
미리 적절한 이행기간을 정하여 문서로 **계고**(기 31조3항 **判**) 건축주 등이 장기간 시정명령을 이행하지 않았더라도, 그 기간 중에는 시정명령의 이행 기회가 제공되지 아니하였다가 뒤늦게 시정명령의 이행 기회가 제공된 경우, 이행기회 제공을 전제로 한 **1회분의 이행강제금만 부과할 수 있고, 이행 기회가 제공되지 않았던 과거의 기간에 대한 이행강제금까지 한꺼번에 부과할 수는 X**
判) 의무자가 이행강제금이 부과되기 전에 그 의무를 이행한 경우, 비록 시정명령에서 정한 기간을 지나서 이행한 경우라도 이행강제금을 부과할 수 없다.

직접강제(행정기본법 제30조 제1항 제3호, 제 32조)
행정상 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 의무자의 신체나 재산에 실력을 행사하여 그 행정상 의무의 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현
국민인권을 가장 크게 제약하므로 최후수단성

강제징수 (기 제30조 제1항 제4호)
의무자가 행정상 의무 중 금전급부 의무를 이행하지 아니하는 경우 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 그 행정상 의무가 실현된 것과 같은 상태를 실현

제2장 행정상 즉시강제

행정상 즉시강제 [14-2]

1. 의의
즉시강제란 급박한 행정상 장애 제거를 위해 미리 의무를 명할 시간적 여유가 없거나 성질상 의무를 명하여 목적달성이 곤란할 때 즉시 국민의 신체·재산에 실력을 가하는 강제수단이다(**행정기본법 제30조 제1항 제5호**).

2. 절차
즉시강제를 실시하기 위해 현장에서 파견되는 집행책임자는 그가 집행책임자임을 표시하는 증표를 보여주어야 하며, 즉시강제의 이유와 내용을 고지하여야(**기33조2항**)

3. 한계
다른 수단으로는 행정목적 달성을 할 수 없는 경우에만, 이 경우에도 최소한으로만 실시하여야(**기 33조1항**)

제3장 행정벌

<★> 행정벌 [21-1]

1. 의의
행정법상의 과거의 의무위반에 대하여 과하는 제재로서의 벌.
행정형벌: **행정벌 중에서** 형법에 정해진 형(사정금자자벌 구과물)을 과하는 것
행정징서법: 행정벌 중 과태료를 과하는 경우

2. 행정벌과 제재적 처분과의 관계
행정처분과 형벌은 각각 그 권력적 기초, 대상 목적이 다르다. 일정한 법규 위반 사실이 행정처분의 전제사실이자 형사법규의 위반의 사실이 되는 경우 동일한 행위에 관하여 독립적으로 행정처분이나 형벌을 부과하거나 **이를 병과할 수 있다.**

제4장 새로운 실효성 확보수단

<★> 과징금 [변11]

행정청은 법령등에 따른 의무를 위반한 자에 대하여 법률로 정하는 바에 따라 그 위반행위에 대한 제재로서 과징금을 부과할 수 있다. (**행정기본법 제28조 제1항**)
☞ 벌금과 병과 가능, 과징금부과처분은 항고소송 대상

<★★> 법위반사실의 공표 [21-1, 15-3]

행정처분

1. 의의(행정기본법 제30조 제1항 제2호)
행정청은 법령에 따른 의무를 위반한 자의 성명, 법인명, 위반사실, 의무 위반을 이유로 한 처분사실 등을 법률로 정하는 바에 따라 일반인에게 공표할 수 있다 (절차40조의3 1항)

2. 공표의 처분성
학: ① 위법한 공표행위에 대하여 다른 적절한 구제수단이 없는 경우에는 공표행위도 **공권력의 행사에 준하는 작용**으로 보아 그 처분성을 인정할 수 있다는 **긍정설**
② 공표행위를 **비권력적 사실행위**로 보아 처분성을 가지지 않는다는 **부정설**
판: 병무청장이 병역의무 기피자의 인정사항 등을 인터넷 홈페이지에 게시하는 등의 방법으로 공개한 경우 병무청장의 공개결정을 항고소송의 대상이 되는 **행정처분으로 보아야** 한다.

3. 공표의 절차와 방법
객관적이고 타당한 증거와 근거 있는지 확인(절40조의3 제2항). 통지+의견제출 기회(절40조의3제3항)

제5편 행정구제법

제1장 국가배상

<★★★> 공무원의 불법행위에 대한 배상 [변8, 모고다수] 1. 의의(국가배상법 제2조 제1항, 법전에 없음) 국가나 지방자치단체는 ① 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인이 ②직무를 집행하면서 ③고의 또는 과실로 ④법령을 위반하여 ⑤타인에게 손해를 입힌 ⑥상당인과관계가 있다면 그 손해를 배상하여야 한다. 공.직.고.위.손.상 ☞ 법전에 없으므로 '국가배상법 제2조 제1항' 암기 2. 배상책임의 요건 (1) 공무원 국가배상법 제2조 소정의 공무원이라 함은 국가공무원법이나 지방공무원법에 의하여 공무원으로서의 신분을 가진 자에 국한하지 않고, 널리 공무를 위탁받아 실질적이고 공무에 종사하고 있는 일체의 자를 가리키는 것으로서, 공무의 위탁이 일시적이고 한정적인 사항에 관한 활동을 위한 것이라도 달리 볼 것은 아니다(判例) (2) 직무집행 가. 직무집행의 범위 判) 권력적 작용뿐만 아니라 비권력적 작용도 포함 o. 단순한 사경제의 주체로서 하는 작용은 포함 x 判)'직무를 집행하면서' = 행위 자체의 외관을 객관적으로 관찰하여 공무원의 직무집행으로 보여질 때 나. 사법작용 判)재판: 법관이 위법하거나 부당한 목적을 가지고 재판하는 등 특.사 있어야 判) 재판에 대하여 따로 불복절차 또는 시정절차가 마련되어 있는 경우에는 불복에 의한 시정을 구할 수 없었던 것 자체가 법관이나 다른 공무원의 귀책사유로 인한 것이라거나 부득이한 사정이 있었다는 등의 특.사 없는 한 원칙적으로 국가배상에 의한 권리구제를 받을 수 없다. 다. 공무원의 부작위 判)공무원에 대하여 작위의무를 명하는 법령의 규정이 없다면 공무원의 부작위로 인하여 침해된 국민의 법익 또는 국민에게 발생한 손해가 어느 정도 심각하고 절박한 것인지, 관련 공무원이 그와 같은 결과를 예견하여 그 결과를 회피하기 위한 조치를 취할 수 있는 가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야. 判)권한 행사가 공무원의 전문적 판단에 기한 합리적인 재량에 위임되어 있더라도 구체적 상황 하에서 공무원에게 그러한 조치권한을 부여한 취지와 목적에 비추어 볼 때 그 불행사가 현저하게 불합리하다고 인정되는 경우, 국가는 그로 인하여 피해를 입은 자에 대하여 국가배상 책임을 부담한다.

<★★★> 공무원의 불법행위에 대한 배상 [변8, 모고다수] 제반사정을 종합 (3) 고의 과실 가. 의의 공무원이 그 직무를 수행함에 있어 당해직무를 담당하는 평균인이 보통 갖추어야 할 주의의무를 게을리 한 것 나. 법령해석의 오류 법령에 대한 해석이 명백하지 않은 경우 관계 공무원이 나름대로 신중을 기하여 합리적 근거를 찾아 내린 해석이 후에 대법원이 내린 입장과 같지 않아 결과적으로 잘못된 해석에 돌아가는 경우에까지 국가배상법상 공무원의 과실을 인정할 수는 없다. 법률에 근거한 행정처분이 사후에 그 처분의 근거가 되는 법률이 헌법에 위반된다고 선언되더라도 그 법률을 적용한 공무원에게 고의 또는 과실이 있다고 단정할 수 없는 것으로, 그 법률이 헌법에 위반되는지 여부는 공무원의 손해배상책임이 성립할지 여부에 아무런 영향 x (4) 위법성 의: 명시적 법령 위반뿐만 아니라 공무원으로서 신의성실 등 마땅히 지켜야 할 준칙이나 규범을 지키지 아니하고 위반한 경우를 포함하여 널리 그 행위가 객관적인 정당성을 결여하고 있는 경우도 포함.(判) 학: ①손해의 불법으로 보는 결과불법설, ②취소소송에서와 같이 행위 자체의 법령위반으로 파악하는 행위불법설, ③행위 자체의 위법뿐만 아니라 피침해이익의 성격과 침해의 정도 등을 종합적으로 고려하여야 한다는 상대적위법성설 판: 행정처분이 객관적 정당성을 상실하였는지 여부는 피침해이익의 종류 및 성질, 침해행위가 되는 행정처분의 태양 및 그 원인, 행정처분의 발동에 대한 피해자측의 관여의 유무, 정도 및 손해의 정도 등 제반사정을 종합하여 판단(상대적 위법성설) (5) 타인에 대한 손해의 발생 스기니 (6) 상당인과관계 判) 공무원에게 직무상 의무를 부과한 법령의 보호목적이 사회 구성원 개인의 이익과 안전을 보호하기 위한 것이 아니고 단순히 공공일반의 이익이나 행정기관 내부의 질서를 규율하기 위한 것이라면, 공무원이 직무상 의무를 위반한 행위와 제3자가 입은 손해 사이에는 상당인과관계가 있다고 할 수 없다. ※민사소송(이행의 소)라서 피고적격/원고적격 실시 X ※항고소송과 병합 청구 O (행소 제10조) 행정행위의 위법 여부가 선결문제인 민사사건(국가배상소송) 학: ①부정설- 행소법 11조 1항에서 '효력 유무 또는 존재 여부'만을 규정(위법여부 언급x) (공정력 있어서) ②긍정설- 행소법 11조 1항 > 예시적인 규정이므로 위법성에 대한 심사 가능 판: 긍정설
--

<★> 군인 군무원 등에 대한 특례 [변8]

1. 의의

군인, 군무원, 경찰공무원 또는 예비군대원이 전투 훈련 등 직무 집행과 관련하여 전사 순직하거나 공상을 입은 경우에 본인이나 그 유족이 다른 법령에 따라 재해보상금 유족연금 상이연금 등의 보상을 지급받을 수 있을 때에는 이 법 및 민법에 따른 손해배상을 청구할 수 없다 (국가배상법 제2조 제1항 단서)

☞ 전투경찰순경은 위 조문의 '경찰공무원'에 해당

☞ '전투 훈련 등 직무집행과 관련하여': 일반 직무집행에 관하여도 국가나 지방자치단체의 배상책임을 제한

2. 국가 등과 사인의 공동불법행위 및 구상권

민간인과 직무집행중인 군인 등의 공동불법행위로 인하여 직무집행중인 다른 군인 등이 피해를 입은 경우, 민간인은 자신의 부담부분에 한하여 손해배상의무를 부담하고, 국가 등에 대하여는 그 귀책부분의 구상을 청구할 수 없다.

<★> 배상책임의 주체

공무원의 위법한 직무행위로 인한 배상책임의 주체는 국가 또는 지방자치단체이며(국가배상법 제2조 제1항), **각각의 사무의 귀속주체**가 책임을 부담하는 것이 원칙이다. 따라서 **자치사무의 경우 지방자치단체가 손해를 배상한다.**

국가나 지자체가 손해를 배상할 책임이 있는 경우 공무원의 선임 감독 또는 영조물의 설치 관리를 맡은 자와 공무원의 봉급 급여, 그 바깥 비용 또는 영조물의 설치 관리 비용을 부담하는 자가 동일하지 아니하면 그 **비용을 부담하는 자도 손해를 배상하여야 한다**(제6조 제1항)

<★> 공무원의 배상책임 [23-3]

1. 구상관계

공무원에게 **고의 또는 중대한 과실**이 있으면 국가나 지방자치단체는 그 공무원에게 구상할 수 있다(제2조 2항)

2. 공무원의 직접적인 배상책임

학: ①**경과실의 경우에도** 책임져야 한다는 **긍정설**, ②국가에게 손해배상을 청구하여야 하며 공무원에게 청구하는 것은 허용되지 않는다는 **부정설**, ③ 공무원에게 **고의 또는 중과실**이 있는 경우에만 책임져야 한다는 **절충설**

판: 고의 또는 중과실 o, 경과실x **절충설**

영조물의 설치나 관리의 하자로 인한 손해배상

1. 의의

도로 하천 그 밖의 공공의 영조물의 설치나 관리에 하자가 있기 때문에 타인에게 손해를 발생하게 하였을 때에는 국가나 지방자치단체는 그 손해를 배상하여야 한다 (국가배상법 제5조 제1항)

공공의 영조물- 행정주체 자신의 사용에 제공되는 공용물도 포함하며, 국가나 지자체가 **사실상의 관리를 하고 있는 경우도 포함한다.**

2. 설치나 관리의 하자

영조물이 공공의 목적에 이용됨에 있어 그 이용상태 및 정도가 일정한 한도를 초과하여 제3자에게 **사회통념상 수인할 것이 기대되는 한도를 넘는 피해를 입히는 경우**까지 포함. 수인한도의 기준을 결정함에 있어서는 **여러 사정을 종합적으로 고려하여 구체적 사건에 따라 개별적으로 결정**

제2장 손실보상

손실보상 [변10]

1. 의의

재산권에 대한 ① 공공필요에 의한 ②적법한 ③공권적 침해로 인하여 발생한 ④특별한 희생에 대한 ⑤행정주체의 보상

2. 희생보상청구권<★>

공권력작용으로 인하여 발생한 비재산적 법익의 침해에 대하여 보상을 청구할 수 있는 권리.

判) **전염병예방법에 의한 피해보상제도**가 수익적 행정처분의 형식을 취하고는 있지만, 실질은 **피해자의 특별한 희생에 대한 보상**에 가깝다.

判) **예방접종과 장애 등 사이의 인과관계**는 반드시 의학적 자연과학적으로 명백히 증명되어야 하는 것은 아니고, 간접적 사실관계 등 **제반 사정을 고려할 때 인과관계가 있다고 추단되는 경우** **증명이 있다고** 보아야.

제3장 행정소송

제1절 행정소송의 종류

I. 항고소송

II. 당사자소송

III. 민중소송

IV. 기관소송

제2절 항고소송의 종류

I. 취소소송

II. 무효등 확인소송

III. 부작위위법확인소송

IV. 법정외 항고소송의 허용 여부

<★> 의무이행소송 [12-3]

1. 의의
당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부 처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정소송
2. 학설(의무이행소송 인정여부)
 - ① 소극설: 권력분립의 관점에서 법원은 행정청에게 특정한 처분의 발령을 명할 수 없다는 견해
 - ② 적극설: 행정소송법 제4조에 규정된 항고소송의 종류는 예시적인 것으로서 判例에 의한 다른 항고소송의 형태를 배제하지 않는다는 견해
3. 판례
행정소송법 제4조에서는 행정심판법상의 의무이행심판 청구에 대응하여 부작위위법확인소송만을 규정하고 있으므로 행정청의 부작위에 대한 의무이행소송은 현행법상 허용되지 않는다고 하여 소극설.

<★★> 예방적 금지소송 [변1,14, 17-3]

1. 의의
장래에 행정청이 일정한 처분을 할 것이 명백한 경우 그 처분을 하지 않을 것을 구하는 내용의 소송
2. 학설(의무이행소송 인정여부)
 - ① 소극설: 예방적 금지소송은 행정청이 일정한 처분을 하기 전에 법원이 해당 권한의 행사를 사전에 차단하는 것으로서 권력분립의 원칙의 관점에서 허용될 수 없다.
 - ② 제한적 허용설: 의무이행소송과 달리 공권력 행사에 대한 소극적 방어행위라고 볼 수 있으므로 허용된다.
3. 판례
행정소송법상 행정청이 일정한 처분을 하지 못하도록 그 부작위를 구하는 청구는 허용되지 않는 부적법한 소송이 다라면서 소극설의 입장이다.

제3절 취소소송의 요건

<★★★> 취소소송의 소송요건 관.원.이.피.심.대.기

- ① 재판관할(행정소송법 제9조), ② 원고적격(제12조 전단), ③ 협의의 소이 이익(제12조 후단) ④ 피고적격(제13조) ⑤ 행정심판전치주의(제18조), ⑥ 대상적격(제19조), ⑦ 제소기간(제20조)

<★★> 재판관할

취소소송의 제1심관할법원은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원으로 한다(행정소송법 제9조 제1항).
일정한 경우 대법원 소재지를 관할하는 행정법원에도 제기할 수 있다(제9조 제2항). 행정법원이 설치되지 않은 지역은 해당 지방법원본원이 관할한다(법원조직법 부칙 제2조).
토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에 이를 제기할 수 있다(제9조 제1항)
법원은 소송의 전부 또는 일부에 대하여 관할권이 없다고 인정하는 경우에는 결정으로 이를 관할법원에 이송(행정소송법 제8조 제2항, 민소법 제34조 제1항).

<★★★★> 원고적격 [변10. 14, 8, 5, 23-2 모고 다수]

1. 의의
취소소송은 처분등의 취소를 구할 법률상 이익이 있는 자가 제기할 수 있다(행정소송법 제12조 전단)
2. 법률상 이익의 의미 (법보,구.보리. 보호 직구 개이익)
학: ① 법률상 보호되는 이익이 침해되는 경우 원고적격을 갖는다는 법률상 보호이익설, ② 위법한 처분으로 인하여 권리를 침해당한 자만 원고적격을 갖는다는 권리구제설, ③ 침해된 이익이 실질적으로 보호할 가치가 있는 이익이라면 원고적격을 갖는다는 보호할 가치가 있는 이익구제설
판: 법률상 보호되는 이익이란 당해 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적·구체적·개별적 이익을 말한다면서, 법률상 보호이익설의 입장이다.
判) 법령이 행정기관으로 하여금 다른 행정기관을 상대로 제재적 조치, 과태료 부과하거나 형사처벌 할 수 있도록 정한 경우, 상대방인 행정기관 등에게 예외적으로 당능, 원고적격 인정 ○
재외동포는 사증발급 거부처분의 취소를 구할 법률상 이익 ○
제약회사는 약제의 상한금액 인하 고시의 원고적격 ○
도로를 이용만 하는 사람은 용도폐지를 다룰 법률상 이익 x

*재결의 직접상대방이 아닌 제3자의 경우에도 행정처분으로 인해 보호되는 법률상 이익을 침해당한 경우에는 원고적격 ○

3. 경업자소송(여러 영업자가 경쟁관계에 있는 경우)

判) 일반적으로 수익적 행정처분의 근거가 되는 법률이 해당 업자들 사이의 과당경쟁으로 인한 경영의 불합리를 방지하는 것도 목적으로 하는 경우, 기존의 업자는 당해처분의 취소를 구할 당사자 적격이 있다.

*약사에게 한약조제권 인정, 한의사들의 영업상 이익 감소. 사실상의 이익에 불과하므로 원고적격 x

4. 경원자소송[24-3, 24-1, 22-3]

수인의 신청을 받아 **우선순위에 따라** 일부에 대해서만 인허가 등의 **수익적 처분**을 하는 경우 심사의 잘못 등으로 우선순위 있는 자신이 아니라 타인에게 허가 등을 하였다고 주장하는 자가 타인이 받은 인허가처분에 대하여 다투는 소송을 말한다. **‘일방 허가 타방 불허가’**

인·허가 등의 수익적 행정처분을 신청한 수인이 서로 경쟁관계에 있어서 일방에 대한 허가 등의 처분이 타방에 대한 불허가 등으로 귀결될 수밖에 없는 때, 허가 등의 처분을 받지 못한 자는 비록 경원자에 대하여 이루어진 **허가** 등 처분의 **상대방이 아니라 하더라도 당해 처분의 취소를 구할 당사자 적격**이 있다.

다만 구체적인 경우에 있어서 그 처분이 **취소된다 하더라도** 허가 등의 처분을 받지 못한 **불이익이 회복된다고 볼 수 없을 때에는** 당해 처분의 취소를 구할 **정당한 이익**이 없다.

5. 인인소송 [24-2, 15-2]

어떠한 시설의 설치를 허가하는 처분에 대하여 당해 시설의 인근주민이 다투는 소송. 判) 행정처분의 근거 법규 또는 관련 법규에 사업으로 인하여 환경상 침해를 받으리라고 예상되는 영향권의 범위가 구체적으로 규정되어 있는 경우, 그 **영향권 내의 주민들에 대하여는** 특단의 사정이 없는 한 **원고적격** 인정되며, 그 **영향권 밖의 주민들은** 자신의 환경상 이익에 대한 **침해** 또는 **침해 우려가 있음을 증명하여야만** 원고적격이 인정된다.

<단체소송의 원고적격> 박도원 169, 정선균 95

1. 단체소송의 의의

단체소송이란 단체 자체의 법률상 이익 침해가 없이 단체가 목적으로 하는 일반적 이익 또는 집단적 이익의 보호를 위하여 제기하는 소송을 의미한다.

2. 단체소송 인정 여부

부정

문: 법률상 이익침해를 전제하지 않는 단체소송은 객관소송의 성격을 가지므로 개별적 법적 근거가 없어도 일반적으로 단체소송이 인정될 수 있는지 문제된다.

<判例>는 **사단법인 대한의사회협회의** 보건복지부 고시로 인한 법률상 이익침해를 부정하였고, 재단법인 수녀원은 쾌적한 환경에서 생활할 환경상 이익의 향유주체가 아니므로 원고적격이 없다고 보았다.

공유수면매립목적 변경 승인처분으로 갑 **수녀원**에 소속된 수녀 등이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 환경상 이익을 침해받는다 하더라도 이를 가리켜 곧바로 갑 수녀원의 법률상 이익이 침해된다고 볼 수 없고, 자연인이 아닌 갑 수녀원은 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 이익을 향수할 수 있는 주체가 아니므로 위 처분으로 위와 같은 생활상의 이익이 직접적으로 침해되는 관계에 있다고 볼 수 없다

<★★★> 협의의 소의 이익 [변12, 4, 모고다수]

1. 의의

행정소송은 본안판결을 구할 정당한 이익 내지 필요가 있어야 한다. 그 처분등의 효과가 소멸된 뒤에도 그 처분등의 **취소로 인하여 회복되는 법률상 이익**이 있는 경우 예외적으로 소의 이익이 인정된다(행정소송법 제12조 후단)

2. 판단 기준

행정처분의 존재로 인하여 국민의 권익이 실제로 침해되고 있는 경우는 물론이고 **권익침해의 구체적 현실적 위험**이 있는 경우에도 소의 이익 인정

3. 원칙 (취소원사)

원칙적으로 ①처분이 이미 취소된 경우, ②처분의 효력기간이 경과하여 이미 소멸, ③ 처분을 취소하더라도 원상회복 불가능, ④처분 이후 사정변경에 의하여 침해가 해소된 경우에는 **소의 이익 X**

判) 대집행의 실행이 완료된 경우 손해배상이나 원상회복 등을 청구하는 것은 별론으로 하고 취소를 구할 **법률상 이익x**

4. 예외

(1) 처분의 외형상 잔존을 이유로 취소의 필요성 인정

직위해제 처분으로 인해 **인사상·급여상 불이익**을 입은 경우

‘회복되는 법률상 이익이 있음’

(2) 가중적 제재요건이 시행규칙으로 정해진 경우

제재적 행정처분의 가중사유나 전제조건에 관한 규정이 법령이 아니라 **규칙의 형식으로 되어 있다고 하더라도**(대외적 구속력x), 행정청은 이를 준수할 의무가 있으므로 그 규칙에 정해진 바에 따라 행정작용을 할 것이 당연히 예견되므로, 선행처분의 취소를 구할 **법률상 이익**이 있다.

(3) 법률상 해명의 필요성이 인정되는 경우

①**위법한 처분이 반복될 위험성**이 있어 해명이 필요, ② 후행처분이 선행처분의 적법함을 전제로 이루어짐에 따라 **선행처분의 하자가 후행처분에 승계**된다고 볼 수 있는 경우 등에는 행정의 적법상 확보와 그에 대한 사법통제, 국민의 권리구제와 확대 측면에서 처분의 취소를 구할 법률상 이익 있다
判) 임시이사 선임처분의 취소소송 계속 중 임기만료 등 사유로 새로운 임시이사들로 교체된 경우, 선행 임시이사 선임처분의 효과가 소멸하였다는 이유로 법률상 이익이 없다고 보면, 무익한 처분과 소송이 반복될 가능성. 따라서 선행처분 취소를 구할 **법률상 이익 O**

(4)경원자 관계

허가 받지 못한 자의 거부처분:

취소판결 확정시 재심사 의무O, 재심사 결과 경원자에 대한 수익적 처분이 직권취소 되고 취소판결의 원고에게 수익적 처분이 이루어질 가능성 완전히 배제할 수 X **소의 이익O**

<★★★> 피고적격 [변6. 24-2, 23-2, 22-2, 16-3 모고 다수]

1. 의의

취소소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다(행정소송법 제13조 제1항). 행정소송은 원칙적으로 소송의 대상인 행정처분 등을 외부적으로 그의 명의로 행한 행정청을 피고로 하여야 한다.

2. 행정청

행정소송법을 적용함에 있어서 행정청에는 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관, 공공단체 및 그 기관 또는 사인이 포함된다(행정소송법 제2조 제2항)

공법인

3. 행정권한의 위임·위탁과 내부위임

判) 내부위임이나 대리권을 수여받은 데 불과하여 원행정청 명의의 대리관계를 밝히지 아니하고는 그의 명의로 처분 등을 할 권한이 없는 행정청이 권한 없이 그의 명의로 한 처분에 대하여도 처분명의자인 행정청이 피고가 되어야 한다.

4. 조례

判) 조례가 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 경우, 피고적격이 있는 행정청은, 행정주체인 지방자치단체 또는 지방자치단체의 내부적 의결기관으로서 지방자치단체의 의사를 외부에 표시한 권한이 없는 지방의회가 아니라, 지방자치단체의 집행기관으로서 조례로서의 효력을 발생시키는 공포권이 있는 지방자치단체의 장이다.

<★★> 행정심판의 전치 [변12, 21-3]

1. 의의

취소소송은 행정심판을 거치지 아니하고 제기할 수 있다. 다만, 다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 때에는 그러하지 아니하다(행정소송법 제18조 1항)
判) 공무원에 대한 징계처분, 그 밖에 본인의 의사에 반한 불리한 처분이나 부작위에 관한 행정소송은 소청심사위원회의 심사 결정을 거치지 아니하면 제기할 수 없다. 공무원(소청심사), 도로교통법(행심), 조세(심사청구), 노동위원회법(재심청구) > 공.도.세.노

2. 필요적 전치주의의 예외

① 동종사건에 관하여 이미 행정심판의 기각재결이 있을 때, ② 서로 내용상 관련되는 처분 또는 같은 목적을 위하여 단계적으로 진행되는 처분중 어느 하나가 이미 행정심판의 재결을 거친 때, ③ 행정청이 사실심의 변론종결 후 소송의 대상인 처분을 변경하여 당해 변경된 처분에 관하여 소를 제기하는 때, ④ 처분을 행한 행정청이 행정심판을 거칠 필요가 없다고 잘못 알린 때(소송 18조3항)
判) '동종사건' = 당해사건은 물론이고 당해 사건과 기본적인 동질성이 있는 사건

<★★★> 대상적격 [출제 다수]

1. 의의

취소소송은 처분등을 대상으로 한다(행정소송법 제19조). 처분등은 ① 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(처분) 및 ② 행정심판에 대한 재결을 말한다(2조1항1호)

2. 처분의 성립요건

일반적으로 행정처분이 ① 주체·내용·절차와 형식이라는 내부적 성립요건과 ② 외부에 대한 표시라는 외부적 성립요건을 모두 갖춘 경우에는 행정처분이 존재한다고 할 수 있다.
c.f) 내부적 전산망 입력- 처분x

(행정의사가 공식적인 방법으로 외부에 표시 여부)

3. 처분의 요소

가, 행정청 (행정기본법 제2조 제2호).

判) 사립학교 교원과 학교법인의 관계- 공법상의 권력관계X
사립학교 교원에 대한 해임처분- 행정청의 처분 X

나. 구체적 사실에 대한 법집행

判) 조례가 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법적 이익에 미치는 등의 법률상 효과를 발생하는 경우 그 조례는 행정처분에 해당

判) 보건복지부 약제급여 비급여 목록 및 급여상한금액표 고시는 다른 집행행위의 매개 없이 그 자체로서 법률관계를 직접 규율하는 성격을 가지므로 행정처분에 해당

다. 공권력의 행사

행정청이 공법에 근거하여 우월적 지위에서 일방적으로 행사하는 행정작용

判) 세무조사결정- 처분성 ○

폐기물처리업 사업계획서의 적정통보를 받은 자만이 허가신청을 할 수 있으므로, 부적정통보는 처분성 ○

불문경고조치가 법률상의 징계처분은 아니지만 징계감경사유로 사용될 수 있었던 표창공적의 사용가능성을 소멸시키는 효과 등이 있다면 행정처분 ○

라. 국민의 구체적인 권리의무에 대한 직접적 변동의 초래

행정청 내부에서의 행위나 알선, 권유, 사실상의 통지 등과 같이 상대방 또는 기타 관계자들의 법률상 지위에 직접적인 법률적 변동을 일으키지 아니하는 행위 등은 항고소송의 대상이 되는 행정처분 X

判) 국가공무원법상 당연퇴직은 결격사유가 있을 때 법률상 당연히 퇴직하는 것이지 공무원관계를 소멸시키기 위한 별도의 행정처분을 요하는 것이 아니므로, 당연퇴직의 인사발령은 관념의 통지에 불과하므로 독립한 행정처분 X

법령의 개정사실, 퇴직연금수급자가 퇴직연금 중 일부 금액의 지급정지대상자가 되었다는 통보는 관념의 통지에 불과 이의신청을 받아들이지 아니하는 결정은 항고소송의 대상 X

4. 권력적 사실행위 [변7, 24-2, 18-1, 14-2, 13-1]

권력적 사실행위는 공권력의 행사로서 일반적으로 특정한 법령 또는 행정행위를 집행하기 위한 사실행위를 말한다.

判) **접견내용 녹음 녹화 및 교도관 참여대상자 지정행위는 계속성을 갖는 공권력적 사실행위**의 성격을 갖고 있으며, 취소할 경우 장래에 이루어질지도 모르는 기본권의 침해로부터 수형자들의 기본적 권리를 구제할 실익이 있는 것으로 보이므로, 구체적 권리의무에 직접적 변동을 초래하는 행정청의 공법상 행위로서 항고소송의 대상이 되는 **처분에 해당한다**.

判) 세무조사결정은 납세의무자의 권리 의무에 직접 영향을 미치는 공권력의 행사에 따른 행정작용으로서 **항고소송의 대상**이 된다.

통고처분- 처분성 X

5. 거부처분 [변2, 5, 9, 23-3, 23-1 모고 다수]

(1) 의의

거부행위란 행정청이 국민으로부터 공권력의 행사를 신청받았으나, 형식적 요건의 불비를 이유로 그 신청을 각하하거나, 이유가 없다면서 신청된 행위를 하지 않겠다는 의사를 표시하는 행위를 말한다.

(2) 거부처분이 되기 위한 요건 (공.법.신)

①신청한 행위가 **공권력의 행사(처분)**이어야 하고, ②신청인의 **법률관계에** 영향을 미치는 행위이어야 하며, ③신청인이 해당 행위를 요구할 수 있는 **법규상 또는 조리상의 신청권**이 있어야 한다(判例)

(3) 신청권의 지위

신청권의 유무를 ①**본안의 문제로** 보는 견해, ②**원고적격의 문제로** 보아야 한다는 견해가 있지만, 判例는 신청의 근거가 된 조항의 해석상 **개인의 신청권을 인정하고 있다면** 그 거부행위는 항고소송의 대상이 되는 **처분으로 보아야** 한다면서 **대상적격의 문제**로 보고 있다(대상적격설).

判例) 도시계획구역 내 토지 등을 소유하고 있는 주민으로서 입안권자에게 도시계획입안을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 **신청권 O**

산업단지 안의 토지 소유자로서 산업단지개발계획에 적합한 시설을 설치하려 입주하려는 자는 **산업단지개발계획의 변경**을 요청할 법규상 또는 조리상 **신청권 O**

문화재보호구역 내에 있는 토지소유자는 보호구역의 지정해제를 요구할 법규상 또는 조리상의 **신청권 O**

수익적 행정행위 신청에 대한 거부처분은 당사자의 신청에 대하여 관할 행정청이 거절하는 의사를 대외적으로 명백히 표시함으로써 성립되고, 거부처분이 있는 후 **다시 신청한 경우** 새로운 신청을 하는 취지라면 행정청이 다시 거절하는 것은 **새로운 거부처분으로 보아야**

일반 개인이 문화재 지정처분으로 인하여 불이익을 입을 우려 있더라도 **취소 또는 해제** 구할 조리상의 **신청권 X**

제소기간이 이미 도과하여 불가쟁력 생긴 행정처분- 변경을 구할 **신청권 X**

스스로 직권취소할 수 있다는 사정만으로 **취소** 요구할 **신청권**이 부여된 것으로 볼 수는 **X**

6. 경정처분

가. 감액경정처분

과세표준과 세액을 감액하는 경정처분은 당초 부과처분과 별개 독립의 과세처분이 아니라 그 실질은 **당초 부과처분의 변경**이므로, 항고소송의 대상은 당초의 부과처분 중 경정결정에 의하여 취소되지 않고 남은 부분이고, 경정결정이 항고소송의 대상이 되는 것이 아니며, 이 경우 적법한 전심절차를 거쳤는지 여부도 **당초 처분**을 기준으로 하여 판단하여야 한다(判例) '당초 환수 처분 중 취소되지 않고 남은 처분'

나. 증액경정처분

증액경정처분을 한 경우에 처음의 과세표준과 세액을 포함하여 전체로서 증액된 과세표준과 세액을 다시 결정하는 것으로 **처음의 과세처분은 소멸**하고 **오직 증액경정처분**만이 쟁송의 대상이 된다

7. 반복된 행위 [변10, 21-3]

가. 원칙

독촉한 후 다시 동일한 내용의 독촉을 하는 경우 **최초의 독촉만이 행정처분**이 되고 그 후에 한 동일한 내용의 독촉은 소멸시효 중단사유가 되는 독촉이 아니라 **민법상의 단순한 최고에 불과**하여 행정처분이라 할 수 없다,

나. 거부처분의 예외

거부처분은 행정청이 국민의 처분신청에 대하여 거절의 의사표시를 함으로써 성립되고, 그 이후 동일한 내용의 신청에 대하여 다시 거절의 의사표시를 명백히 한 경우에는 **새로운 처분이 있는 것으로** 보아야 할 것이다

8. 이의신청[25-3, 23-1, 21-3]

가. 의의: 이의가 있는 당사자는 처분을 받은 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의신청 할 수 있다(행기 제36조 1항)

나. 이의신청 기각결정과 거부처분의 구별

이의신청을 받아들이지 아니하는 결정은 이의신청인의 권리 의무에 새로운 변동을 가져오는 공권력의 행사나 이에 준하는 행정작용이라 할 수 없으므로 원결정과 별개로 **항고소송**의 대상이 되지 않는다.

다. 이의신청 기각결정과 행정심판의 재결의 구별

이의신청은 행정심판법에서 정한 행정심판과는 그 성질을 달리하고 행정심판에 대한 특별·특례절차 X

라. 수익적행정행위의 거부에 대한 이의신청

수익적 행정행위 신청에 대한 거부처분이 있을 후 당사자가 다시 신청을 한 경우에는 신청의 제목 여하에 불구하고 그 내용이 새로운 신청을 하는 취지라면 관할 행정청이 이를 다시 거절하는 것은 새로운 거부처분으로 봄이 원칙이다.

마. **효과** 이의신청을 한 경우에도 그 이의신청과 관계없이 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다(행정기본법 제36조 제3항). 이의신청에 대한 결과를 **통지받은 날부터 90일 이내**에 처분에 대하여 행정심판 또는 행정소송 제기 할 수 O (4항)

9. 재결 [변3, 6 24-2 23-1 13-2]

가. 의의

처분등은 처분뿐만 아니라 행정심판에 대한 재결을 포함하므로(행정소송법 제2조 제1항 제1호), 재결은 취소소송의 대상이 된다(행정소송법 제19조)

나. 원처분주의

취소소송은 처분등을 대상으로 한다. 다만, 재결취소송의 경우에는 **재결 자체에 고유한 위법**이 있음을 이유로 하는 경우에 한한다(행정소송법 제19조).

따라서 재결취소소송의 경우 재결 자체에 고유한 위법이 있는지 여부를 심리할 것이고, 재결 자체에 고유한 위법이 없는 경우에는 **원처분의 당부와는 상관없이** 당해 재결취소소송은 이를 기각하여야 한다

다. 각하재결

행정심판청구가 부적법하지 않음에도 각하한 재결은 심판청구인의 실제심리를 받을 권리를 박탈한 것으로서 **원처분에 없는 고유한 하자**가 있는 경우에 해당. 취소소송의 대상.

라. 일부 인용재결 및 변경재결

원처분을 **유리하게 변경**하는 처분을 한 경우: 변경처분에 의하여 당초 처분은 소멸x, 당초부터 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하는 것이므로 **취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초 처분** (원처분주의도 기재)

마. 제3자요 행정행위에 대한 인용재결

제3자요를 수반하는 행정행위에 대한 행정심판청구에 있어서 그 청구를 인용하는 내용의 재결로 인하여 비로소 권리의익을 침해받게 되는 자는 그 인용재결에 대하여 다룰 필요가 있고, 그 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 **항고소송의 대상 O** (재결에 고유한 하자를 주장)

<★★★> 제소기간 [변6, 8, 3, 모고다수]

1. 원칙

가. 의의

처분등이 있음을 안 날로부터 90일 이내로서 처분등이 있는 날로부터 1년 이내. 단, 정당한 사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다(행정소송법 제20조)

나. 정당한 사유

행정처분의 직접상대방이 아닌 제3자는 행정처분이 있음을 곧 알 수 없는 처지이므로, 특사 없는 한 **정당한 사유**가 있는 때에 해당한다.

다. 처분등이 있음을 안 날부터 90일

통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 상대방이 불특정 다수인이고 그 처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는 것이므로, 이해관계를 갖는 자가 **현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날** 행정처분 있음을 알았다고 보아야

*효력발생일을 밝히고 있지 않으면 고시 후 5일 경과한 때

라. 처분등이 있는 날부터 1년

문서가 송달(**절차14조**)받은 자에게 도달됨으로써 효력 발생(判)혼인해 독립하였으나 일시 방문한 아들에게 전달-인정x

2. 행정심판 청구를 한 경우의 예외

가. 의의

재결서의 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내로서 재결이 있는 날부터 1년 이내에 제기하여야(행정소송법 제20조)

(判) 행정처분이 있음을 안 날부터 **90일을 넘겨** 행정심판을 청구하여 **각하재결**을 받은 후 재결서를 송달받은 날부터 90일 내에 **원래의 처분에 대하여 취소소송**을 제기한 경우, 취소소송의 **제소기간을 준수한 것으로 볼 수 없다**

나. 변경처분

행정청이 영업자에게 행정제재처분을 한 후 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 그 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초 처분이지 변경처분은 아니므로, **제소기간의 준수 여부도 변경처분이 아닌 변경된 처분의 당초 처분을 기준으로**

3. 처분에 대한 이의신청을 한 경우의 예외

이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 행정심판 or 행정소송 제기 **可**(행정기본법 제36조 제4항)

4. 일반처분을 고시 또는 공고에 의하여 하는 경우[변8]

통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우 그 처분의 상대방이 불특정 다수인이므로, 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자가 고시 또는 공고가 있었음을 **현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날 행정처분이 있음을 알았다고 보아야**(判)

*제소기간 도과한 경우 무효확인소송/하자의 승계 검토

제4절 취소소송의 당사자

<★★> 당사자능력 [변14]

가. 당사자능력의 범위

행정소송에 관하여 행정소송법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 **민사소송법**의 규정을 **준용**하므로(**행정소송법 제8조 제2항**), ①자연인과 법인은 당사자가 될 수 있고(**민사소송법 제51조**), ②법인이 아닌 사단이나 재단은 대표자 또는 관리인이 있는 경우에는 그 사단이나 재단의 이름으로 당사자가 될 수 있다(**민사소송법 제52조**).

나. 행정기관의 피고적격

취소소송은 특별한 규정이 없는 한 그 처분등을 행한 행정청을 피고로 한다(**행정소송법 제13조 제1항 본문**)

행정소송법은 행정기관에게 원칙적으로 당사자능력이 없음에도 불구하고, 소송수행의 편의를 위하여 처분을 행한 행정청에게 피고적격을 인정하고 있다

라. 행정기관에 당사자능력이 인정되는 경우

법령이 특정한 행정기관 등으로 하여금 다른 행정기관을 상대로 제재적 조치를 취할 수 있도록 하면서, 그에 따르지 않으면 그 행정기관에 대하여 과태료를 부과하거나 형사처벌을 할 수 있도록 정하는 경우, 제재적 조치의 상대방인 행정기관 등에게 항고소송 원고로서의 당사자능력과 원고적격을 인정할 수 있다(判例)

피고경정

원고가 피고를 잘못 지정한 때에는 법원은 원고의 신청에 의하여 결정으로써 피고의 경정을 허가할 수 있다(**행정소송법 제14조 제1항**). 이 경우 새로운 피고에 대한 소송은 처음에 소를 제기한 때에 제기된 것으로 본다(**행정소송법 제14조 제4항**)

☞ 민소에 비해 너그러운 편

<★> 소송참가 [12-2]

1. 제3자의 소송참가

법원은 소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해를 받을 제3자가 있는 경우에는 당사자 또는 제3자의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 제3자를 소송에 참가시킬 수 있다(**행정소송법 제16조 제1항**), 처분등을 취소하는 확정판결은 제3자에 대하여도 효력이 있기 때문이다(**행정소송법 제29조 제1항**).

2. 행정청의 소송참가

법원은 다른 행정청을 소송에 참가시킬 필요가 있다고 인정할 때에는 당사자 또는 당해 행정청의 신청 또는 직권에 의하여 결정으로써 그 행정청을 소송에 참가시킬 수 있다(**행정소송법 제17조 제1항**)

제5절 취소소송의 제기

<★★> 소송의 병합 [변7, 20-2]

취소소송에는 사실심의 변론종결시까지 ①당해 처분등과 관련되는 손해배상·부당이득반환·원상회복등 청구소송 및 ② 당해 처분등과 관련되는 취소소송을 병합하거나, 피고외의 자를 상대로 한 관련청구소송을 취소소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다(**행정소송법 제10조 제2항**).

判) 행정처분에 대한 **무효확인**과 **취소청구**는 서로 **양립할 수 없는 청구**로서 **주위적·예비적 청구**로서만 병합이 가능하고 선택적 청구로서의 병합이나 단순 병합은 허용되지 아니한다. **항고소송- 민사소송, 당사자소송과 병합 O**

<★> 사건의 이송 [18-2]

법원은 소송의 전부 또는 일부에 대하여 관할권이 없다고 인정하는 경우에는 결정으로 이를 관할법원에 이송한다(**행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제34조 제1항**)

<★★> 소의 변경 [18-2]

법원은 취소소송을 당사자소송으로 변경하는 것이 상당하다고 인정할 때에는 청구의 기초에 변경이 없는 한 사실심의 변론종결시까지 원고의 신청에 의하여 결정으로써 소의 변경을 허가할 수 있다(**행정소송법 제21조 제1항**). 이는 당사자소송을 항고소송으로 변경하는 경우에도 준용된다(**행정소송법 제42조**)

법원은 행정청이 소송의 대상인 처분을 소가 제기된 후 변경한 때에는 원고의 신청에 의하여 결정으로써 청구의 취지 또는 원인의 변경을 허가할 수 있다(**행정소송법 제22조 제1항**)

<★★★> 행정소송에서의 입시구제 [변9, 2, 13-1]

1. 집행정지(행정소송법 제23조)

가. 요건 **이재(계)명 회 공급**

① 집행정지의 이익이 존재하고, ② 적법한 본안소송이 계속 중이며, ③본안청구의 이유없음이 명백하지 않고, ④회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여, ⑤긴급한 필요가 있으며, ⑥ 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 없어야 한다.

判) '회복하기 어려운 손해'란 특사 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 금전보상으로는 사회관념상 행정처분을 받은 자가 참고 견딜 수 없거나 현저히 곤란한 경우의 유형, 무형의 손해를 일컫는다.

'공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려'- 당해 처분의 집행과 관련된 구체적 개별적인 공익에 중대한 해를 미칠 개연성

나. 거부처분에 대한 집행정지의 불인정

신청에 대한 거부처분의 효력을 정지하더라도, 거부처분이 없었던 것과 같은 상태 즉 거부처분이 있기 전의 신청시의 상태로 되돌아가는 데에 불과하고 행정청에게 신청에 따른 처분을 하여야 할 의무가 생기는 것이 아니므로, 거부처분의 효력정지는 그 거부처분으로 인하여 신청인에게 생길 손해를 방지하는 데에 아무런 소용이 없어 그 효력정지를 구할 이익이 없다.

다. 집행정지결정의 효력

효력기간이 정해져있는 제재적 행정처분에 대한 취소소송에서 법원이 본안소송의 판결 선고 시까지 집행정지결정을 하면, 처분에서 정해 둔 효력기간은 판결 선고 시까지 진행하지 않다가 판결이 선고되면 그때 집행정지결정의 효력이 소멸함과 동시에 처분의 효력이 당연히 부활하여 처분에서 정한 효력기간이 다시 진행된다.

최판) 의대정원 증원(2024무689 결정)

보건복지부장관의 증원발표는 행정청의 내부적인 의사결정. 교육부장관의 증원배정은 항고소송의 대상이 되는 처분. 의대 재학 중인 신청인들은 증원배정 처분 중 자신이 재학 중인 의과대학에 대한 부분의 집행정지를 구할 법률상 이익이 있지만, 증원배정의 집행이 정지됨으로써 공공복리에 중대한 영향이 발생할 우려가 크다는 이유로, 증원배정에 대한 집행정지는 허용되지 않는다.

2. 민사집행법상 가처분 준용여부

학: ①가처분이 인정되면 법원이 일정한 행위를 행정기관에 명령하게 되므로 권력분립원칙에 어긋나 인정될 수 없다는 부정설, ②가처분을 인정함으로써 사법에 의하여 실효성 있는 권리구제가 이루어지므로 민사집행법을 준용하는 행정소송법의 일반 조항이 적용된다는 긍정설

판: 항고소송에 있어서는 행정소송법 제8조 제2항에 불구하고 민사집행법 중 가처분에 관한 규정은 준용되지 않는다고 하여 부정설의 입장이다

제6절 행정소송의 심리

<★> 직권심리 [16-3]

의: 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다(행정소송법 제26조).

학: ①행정소송은 사적자치의 원칙이 지배하지 않는 공법상 법률관계를 그 대상으로 할 뿐만 아니라 행정소송법 제26조의 규정취지상 직권탐지주의가 적용된다는 직권탐지주의설, ②가사소송법처럼 명문으로 직권주의를 채택하는 규정이 없는 이상 행정소송의 경우에도 원칙적으로 변론주의가 적용된다는 변론주의보충설

판: 행정소송법 제26조의 규정이 변론주의의 일부 예외를 인정하고 있으므로, 행정소송에서는 법원이 필요하다고 인정할 때에는 당사자가 명백하게 주장하지 않는 사실이라 할지라도 기록에 나타난 자료를 기초로 하여 직권으로 심리조사하고 이를 토대로 판단할 수 있다면서 변론주의보충설의 입장이다.

判) 법원은 아무런 제한 없이 당사자가 주장하지도 않은 사실을 판단할 수 있는 것은 아니고 일견 기록상 현출되어 있는 사항에 관하여서만 이를 직권으로 심리 조사하고 이를 기초로 하여 판단할 수 있을 따름이다.

<★★> 심리판단의 기준시 [변9, 22-1, 19-1]

1. 소송요건: 사실심변론종결 시는 물론 상고심에서도 존속해야

2. 본안요건

가. 처분의 위법판단 → 처분 당시

새로운 법령등은 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 그 법령등의 효력 발생 전에 완성되거나 종결된 사실관계 또는 법률관계에 대해서는 적용되지 아니한다(행정기본법 제14조 제1항).

나. 신청에 의한 처분의 위법 판단

당사자의 신청에 따른 처분은 법령등에 특별한 규정이 있거나 처분 당시의 법령등을 적용하기 곤란한 특사가 있는 경우를 제외하고는 처분 당시의 법령등에 따른다.(기14조2항)

判) 허가신청 후 허가기준이 변경되었다하더라도 행정청이 허가신청을 수리하고도 이유 없이 처리를 늦추어 그 사이에 허가기준이 변경된 것이 아닌 이상 새로운 허가기준에 따라서 처분을 하여야 한다.

다. 제재적 처분의 대상행위에 대한 위법 판단

법령등을 위반한 행위의 성립과 이에 대한 제재처분은 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 법령등을 위반한 행위 당시의 법령등에 따른다(기 제14조 제3항 본문).

다만, 법령등을 위반한 행위 후 법령등의 변경에 의하여 그 행위가 법령등을 위반한 행위에 해당하지 아니하거나 제재처분 기준이 가벼워진 경우로서 해당 법령등에 특별한 규정이 없는 경우에는 변경된 법령등을 적용한다(기 14조3항 단서).

<★★★> 처분사유의 추가·변경 [12, 22-1, 20-3, 19-3 등]

기사동

1. 의의
처분사유의 추가·변경이란 행정청이 항고소송 심리 과정에서 당해 처분을 유지하기 위하여 처분 당시에 제시된 처분사유 이외에 다른 사유를 추가하거나 변경하는 것

(행소규 제9조)

2. 허용여부

학: ①취소소송의 소송물은 '위법성 일반'이므로, 처분시에 간과하고 있던 새로운 사유를 취소소송 진행 중에 주장하는 데 제한이 없다는 **긍정설**, ②행정청은 처분시 그 처분의 이유를 한번 명시한 이상 그 이유에 구속되어 새로운 사유를 추가 또는 변경하여 주장할 수 없다는 **부정설**, ③원래의 처분사유와 기본적 사실관계가 동일한 범위 내에서만 처분사유의 추가 또는 변경이 허용된다는 **제한적 긍정설**이 대립한다.

판: 항고소송에서 처분청은 **당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에** 서만 다른 사유를 추가 또는 변경할 수 있다면서, **제한적 긍정설**의 입장이다.

*判) 도로법과 구 국유재산법령 및 구 공유재산 및 물품관리법령의 해당 규정은 입법취지, 변상금의 징수목적, 산정기준금액, 재량 유무, 절차 등이 달라 근거 법령을 변경하는 것은 동일성을 인정할 수 없는 별개의 처분을 하는 것과 다름없어 허용될 수 없다.

判) 입찰참가자격을 제한시킨 당초의 처분 사유인 **정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않은 사실**과 계약의 이행과 관련하여 **관계 공무원에게 뇌물을 준 사실**은 **기사동 X**

3. 시간적 한계

행정청은 **처분 이전에** 발생한 다른 사유를 **사실심 변론종결 시까지만** 추가, 변경할 수 있다

최판) 2019두38465 처분의 기존 근거법령('보조금 지원대상에서 제외한다')는 **기속행위로**, 추가된 근거법령('보조금 교부를 제한할 수 있다')는 **재량행위로** 규정하고 있으므로 근거법령의 추가를 통해 제외처분의 성질이 **기속행위에서 재량행위로** 변경되는 것. 양정사실 새로 고려되어야 하므로 **기사동X**

2023두61349 기사동x 사실의 처사추 허용되지 않는다고 해석하는 이유는 **상대방의 방어권 보장, 실질적 법치주의** 구현, 상대방에 대한 **신뢰 보호** 취지이므로 상대방이 기존의 거부처분과 기사동X 인 추가·변경된 처분사유의 심리 판단에 **명시적으로 동의하는 경우, 기사동 여부와 무관하게** 예외적으로 처사추 허용할 수 O

제7절 행정소송의 판결

<★★> 일부취소판결 [변3, 22-3 17-2 15-3]

가분성

취소소송은 행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경(**입법실수**)하는 소송으로 규정하는데(**행정소송법 제4조 제1호**), 여기서 변경하는 소송은 일부를 취소하는 판결을 말하고, 처분 내용을 적극적으로 변경하는 판결은 허용되지 않는다.

처분을 할 것인지 여부와 처분의 정도에 관하여 그 명령이 재량권을 일탈하였을 경우, 법원으로서 재량권의 일탈 여부만 판단할 수 있을 뿐이지 재량권의 범위 내에서 어느 정도가 적정한 것인지에 관하여는 판단할 수 없어 그 **전부를** 취소할 수밖에 없고, 법원이 적정하다고 인정하는 부분을 초과한 부분만을 취소할 수 없다. (**생략** 可)

☞ 재결은 적극적 변경 가능.

문: 일부취소판결의 가능성

判: 외형상 하나의 행정처분이라 하더라도 **가분성**이 있거나 그 처분대상의 일부가 특정될 수 있다면 **일부만의 취소**도 가능하고 그 일부의 취소는 당해 취소부분에 관하여만 효력이 생긴다.

* 判) 레이카크레인을 음주운전한 행위는 제1종 특수면허의 취소사유에 해당될 뿐 제1종 보통 및 대형 면허의 취소사유는 아니므로, 3종의 면허를 모두 취소한 처분 중 보통 및 대형 면허에 대한 부분은 **일부 취소 O**

여러 종류의 자동차운전면허를 취소 또는 정지하는 경우 서로 별개의 것으로 취급하는 것이 원칙이나, 제1종 보통면허로 운전할 수 있는 차량의 음주운전은 제1종 대형면허로도 가능하고, 또한 제1종 대형면허나 제1종 보통면허의 취소에는 당연히 원동기장치자전거의 운전까지 금지하는 취지가 포함된 것이어서 제1종 보통면허로 운전할 수 있는 차량을 음주운전한 경우에 이와 관련된 면허인 제1종 대형면허와 원동기장치자전거면허까지 취소할 수 있는 것으로 보아야 한다.

<★★> 사정판결 [15-1, 12-2]

1. 의의 (**행정소송법 제28조 제1항**)

원고의 청구가 이유있다고 인정하는 경우에도 처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 법원은 원고의 청구를 기각할 수 있다

2. 요건: ①원고의 청구가 이유있고, ②처분등을 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 않아야 한다.

判) 사정판결의 요건에 해당하는지는 위법·부당한 행정처분을 취소·변경하여야 할 필요와 취소·변경으로 발생할 수 있는 공공복리에 반하는 사태 등을 비교·형량하여 엄격하게 판단하여야 한다.

3. 효과 (**행정소송법 제28조, 제32조**)

청구기각+처분 위법 명시+손해와 배상방법 조사, 소송비용 피고 부담

<★★> 기판력 [변7, 12, 4, 24-2, 16-2] **상대적위법성설**

1. 의의(행소 제8조 제2항, 민소 제216조 제1항)

확정판결은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력을 가진다.

2. 객관적 범위

판결의 주문은 소송물에 대한 판단이며, 취소소송의 소송물은 그 취소원인이 되는 위법성 일반이다. 기판력이 판결이유에 설치된 그 전제가 되는 법률관계의 존부에까지 미치는 것은 아니다.

3. 후속 국가배상소송과의 관계

학 : ①취소판결의 기판력이 인용판결이든 기각판결이든 불문하고 국가배상청구소송에 미친다는 **협의의 행위위법설**, ②취소판결의 인용판결만 기판력이 국가배상청구에 미친다는 **광의의 행위위법설**, ③취소소송의 기판력이 국가배상청구소송에 미치지 않는다는 **상대적 위법성설**이 대립한다.

판 : 어떠한 행정처분이 후에 항고소송에서 취소되었다고 할지라도 그 기판력에 의하여 당해 행정처분이 곧바로 공무원의 고의 또는 과실로 인한 것으로서 **불법행위를 구성한다고 단정할 수 없다**면서, **상대적 위법성설**.

*判) **행정소송의 수소법원이 관련 확정판결의 사실인정에 구속되는 것은 아니지만**, 관련 확정판결에서 인정한 사실은 행정소송에서도 유력한 증거자료가 되므로, 특사 없는 한 이와 반대되는 사실 인정할 수 X.

<★★★> 기속력 [변12, 9, 2 모고 다수]

이유증 판단-특수효력설. 기사동. 반재.결. 중대명백

1. 의의 (행정소송법 제30조 제1항)

처분등을 취소하는 확정판결은 그 사건에 관하여 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.

2. 성질

학 : ①취소판결의 실효성을 담보하기 위하여 실정법이 부여한 특수한 효력이라는 **특수효력설**, ②기속력은 소송법적 효력인 기판력의 존중의무나 집행의무라는 **기판력설**

판 : 확정판결의 기속력은 주로 판결의 실효성 확보를 위하여 인정되는 효력으로서 판결의 **주문뿐만 아니라** 그 전제가 되는 처분 등의 구체적 위법사유에 관한 **이유 중의 판단에 대하여도** 인정된다면서 **특수효력설**

3. 범위

가. 주관적 범위(행정소송법 제30조 제1항) 주. 객. 시 당사자인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다.

나. 객관적 범위

확정판결의 기속력은 종전 처분과 다른 사유를 들어서 새로이 처분을 하는 것은 미치지 않는다. 여기에서 동일 사유인지는 확정판결에서 위법한 것으로 판단된 종전 처분사유와 **기본적 사실관계에서 동일성**이 인정되는지 여부에 따라 판단되어야 한다.

다. 시간적 범위

행정처분의 적법 여부는 **그 행정처분이 행하여진 때**의 법령과 사실을 기준으로 하여 판단하는 것이므로 **처분 후의 새로운 사유**를 들어 다시 이전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있다.

4. 내용 (반재.결)

가. 반복금지효

判) 행정청은 그 **위법사유를 보완하여 다시 새로운 처분**을 할 수 있고, 그 새로운 처분은 취소된 종전의 처분과는 별개의 처분이어서 기속력에 저촉 X

나. 재처분의무

취소되는 처분이 거부처분인 경우, 그 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야(제30조 2항)

①신청에 따른 처분이 ②**절차의 위법**을 이유로 취소되는 경우에도 마찬가지로 재처분을 하여야 한다.(제30조 3항)
행정처분의 적법 여부는 처분 시의 법령과 사실을 기준으로 판단하는 것이므로 처분 행정청은 **종전 처분 후에 발생한 새로운 사유를 내세워 다시 거부처분**을 할 수 있다.

다. 결과제거의무(원상회복의무): 명문규정X, 判例는 인정

5. 기속력 위반의 효과

기속력 위반의 행정처분은 그 하자가 **중대하고 명백한 것**이어서 **당연무효**

<★> 간접강제(집행력) [변2]

행정청이 거부처분의 취소판결에 의한 처분을 하지 아니하는 때에는 제1심 수소법원은 당사자의 신청에 의하여 결정으로써 상당한 기간을 정하고 행정청이 그 기간내에 이행하지 아니하는 때에는 그 지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하거나 즉시 손해배상을 할 것을 명할 수 있다(행정소송법 제34조 제1항)

<★★> 무효등 확인소송 [변16, 20-2]

관원이피대 보충성 필요X

1. 무효등 확인소송의 소송요건

①재판관할(행정소송법 제9조, 제38조 제1항), ②원고적격(제35조), ③협회의 소의 이익(제35조), ④피고적격(행정소송법 제13조, 제38조 제1항), ⑤대상적격(행정소송법 제19조, 제38조 제1항)

2. 협회의 소의 이익(확인이익)

행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우에는 행정소송법 제35조에 규정된 '무효확인을 구할 법률상 이익'이 있다고 보아야 하고, 이와 별도로 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것은 아니므로 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지(보충성) 여부를 따질 필요가 없다고 해석함이 타당하다(判例)

<★★> 부작위위법확인소송 [22-2, 12-3]

신의 기부. 법규상 또는 조리상의 신청권.

원고적격의 문제인 동시에 대상적격의 문제

1. 의의 (행정소송법 제2조 제1항 제2호, 제4조 제3호)

행정청이 ①당사자의 신청에 대하여, ②상당한 기간내에, ③일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고, ④이를 하지 아니하는 경우(처분의 부존재), 행정청의 부작위가 위법하다는 것을 확인하는 소송. (신의.기.부)

2. 요건

항고소송의 대상이 되는 위법한 부작위가 된다고 하기 위하여는 국민이 행정청에 대하여 그 신청에 따른 행정행위를 해 줄 것을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 권리가 있어야 한다. (判)

3. 신청권의 지위

학: 신청권의 유무를 ①본안의 문제로 보는 견해, ②원고적격의 문제로 보는 견해, ③대상적격의 문제로 보는 견해
판: 법규상 또는 조리상 권리를 갖고 있지 아니한 경우에는 원고적격이 없거나 항고소송의 대상인 위법한 부작위가 있다고 볼 수 없다면서 원고적격의 문제로 보는 동시에 대상적격의 문제로 보고 있다.

4. 제소기간

원칙: 부작위상태가 계속되는 한 제소기간의 제한 X

예외: 행심 등 전심절차를 거친 경우 행소법 제20조의 제한

제10절 당사자소송

<★★> 당사자소송 [변13, 2, 23-2, 22-2, 19-1]

1. 의의

행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송.(행정소송법 제3조 제2항)

2. 항고소송과 당사자소송의 구별

항고소송은 우월한 지위에서 갖는 공권력의 행사 불행사와 관련된 분쟁을 해결하기 위한 절차인데 반해(소송 제3조1호), 당사자소송은 그러한 공권력의 행사 불행사의 결과로서 생긴 법률관계에 관한 소송, 그 밖의 대등한 당사자 간의 공법상 권리의무에 관한 소송이다(소송 제3조 제2호)

①어떤 급부청구권이 행정청의 인용결정에 의하여 비로소 발생하는 경우에는 신청에 대한 행정청의 거부결정을 대상으로 항고소송을 제기하여야 하고, ②행정청의 1차적 판단이 필요없이 법령에 의하여 곧바로 구체적인 청구권이 발생하는 경우에는 당사자소송을 제기하여야 한다.

判) 상이연금 등의 급여를 받을 권리는 국방부장관이 인정함으로써 비로소 구체적인 권리가 발생하므로, 그 인정 청구를 거부하는 처분의 경우 항고소송의 대상

判) 공무원연금관리공단의 인정에 의하여 퇴직연금을 받아 오던 중 법령의 개정 등으로 퇴직연금 중 일부 금액의 지급이 정지된 경우, 당연히 개정된 법령에 따라 퇴직연금이 확정되는 것이므로 공법상 당사자 소송의 대상.

判) 도시 및 주거환경정비법상 행정주체인 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 조합 총회결의의 효력 등을 다투는 소송은 관리처분계획이라는 행정처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송으로서 그 소송결과에 따라 행정처분이 위법 여부에 직접 영향을 미치는 공법상 법률관계에 관한 것이므로, 이는 행정소송법상의 당사자소송에 해당한다.

주택~조합은 공법인. 근데 계획'안'에 대한 결의는 처분 X. ∴당사자소송

지방소방공무원의 초과근무수당 지급청구권은 법령의 규정에 의하여 요건에 해당하는 경우 곧바로 발생한다고 할 것이므로, 지방소방공무원이 자신이 소속된 지방자치단체를 상대로 초과근무수당 지급을 구하는 청구에 관한 소송은 당사자소송의 절차에 따라야

3. 피고적격(행정소송법 제39조)

국가·공공단체 그 밖의 권리주체

* 민사소송과 비슷하나 민소는 사법상법률관계, 당사자소송은 공법상 법률관계

제4장 행정심판

<★★> 취소심판 [23-1, 16-3]

취소심판이란 행정청의 위법 또는 부당한 처분을 취소하거나 변경하는 행정심판을 말한다(행정심판법 제5조 제1호)

의무이행심판이 존재함에도 불구하고 **거부처분에 대하여 취소심판을 제기할 수 있으며**(행정심판법 제49조 제2항), 당사자의 신청을 거부하는 처분을 취소하는 재결이 있는 경우에는 행정청은 그 재결의 취지에 따라 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다(判例).

무효등 확인심판

행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 행정심판을 말한다(행정심판법 제5조 제2호)

<★★★> 의무이행심판 [23-1, 22-2, 17-1, 16-3, 12-3]

1. 의의

의무이행심판이란 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 행정심판을 말한다(행정심판법 제5조 제3호)

2. 원고적격

의무이행심판은 처분을 신청한 자로서 행정청의 거부처분 또는 부작위에 대하여 일정한 처분을 구할 법률상 이익이 있는 자가 청구할 수 있다(행정심판법 제13조 제3항)

제2절 행정심판의 제기

<★> 고지제도 [변11]

1. 의의 (행정심판법 제58조 제1항)

행정청이 처분을 할 때에는 처분의 상대방에게 **행정심판 청구가능성, 그 절차 및 청구기간**을 알려야 한다.

2. 고지의무 위반의 위법성

고지절차의 규정은 상대방이 그 처분에 대한 행정심판 절차를 밟는 데 있어 편의를 제공하려는 데 있어 처분청이 고지의무를 이행하지 아니하였다고 하더라도, 경우에 따라서는 **행정심판의 제기기간이 연장될 수 있는 것**에 그치고 이로 인하여 심판의 대상이 되는 **행정처분에 어떤 하자가 수반된다고 할 수 없다**(判例)

3. 고지의무 위반의 효과 → 청구기간 연장

행정청의 불고지 또는 오고지로 심판청구서를 다른 행정기관에 제출한 경우 심판청구기간은 그 행정기관에 심판청구서가 제출되었을 때에 행정심판이 청구된 것으로 본다(제23조 제4항). 행정청이 심판청구 기간을 알리지 아니한 경우에는 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 심판청구를 할 수 있다(행정심판법 제27조 제3항)

<★★> 행정심판에서의 임시구제 [23-1, 16-3]

거부처분 효력정지 구할 이익X

집행정지로 목적 달성?-임시처분X

1. 집행정지

행정심판위원회는 처분, 처분의 집행 또는 절차의 속행 때문에 중대한 손해가 생기는 것을 예방할 필요성이 긴급하다고 인정할 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 처분의 효력, 처분의 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지를 결정할 수 있다(행정심판법 제30조 제2항)

*判) 신청에 대한 **거부처분의 효력을 정지하더라도** 거부처분이 없었던 것과 같은 상태 즉 거부처분이 있기 전의 신청시의 상태로 되돌아가는 데에 불과하고 **행정청에게 신청에 따른 처분을 하여야 할 의무가 생기는 것이 아니므로**, 거부처분의 효력정지는 그 거부처분으로 인하여 신청인에게 생길 손해를 방지하는 데에 아무런 소용이 없어 그 **효력정지를 구할 이익이 없다**.

2. 임시처분 (임시지위를 구하는 가처분) [22-2, 18-3, 12-3]

행정심판위원회는 ①처분 또는 부작위가 위법·부당하다고 상당히 의심되는 경우로서 ②처분 또는 부작위 때문에 당사자가 받을 우려가 있는 중대한 불이익이나 당사자에게 생길 급박한 위험을 막기 위하여 ③임시지위를 정하여야 할 필요가 있는 경우에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 의하여 임시처분을 결정할 수 있다 (행정심판법 제31조 제1항)

다만, ①임시처분은 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있거나(행정심판법 제31조 제2항, 제30조 제3항), ② **집행정지로 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용 X** (행정심판법 제31조 제3항)

☞ 의무이행심판은 임시구제는 아니지만, 권리구제수단을 묻는다면 의무이행심판도 써줘야 함.

제3절 재결

<★★> 재결의 종류 [변11, 15-3]

가. 취소심판

형성재결인 ① 처분취소재결, ② **처분변경재결**, 이행재결인 ③ **처분변경명령재결** (행정심판법 제43조 제3항)

나. 의무이행심판

형성재결인 ① 처분재결, 이행재결인 ② 처분명령재결이 있다. 행정심판위원회는 처분재결과 처분명령재결의 선택에 재량권을 가지며, 실무상 처분명령재결을 주로 한다.

다. 무효등확인재결

① 처분무효확인재결, ② 처분실효확인재결, ③ 처분유효확인재결, ④ 처분존재확인재결, ⑤ 처분부존재확인재결이 있다.

<★> 인용재결의 기속력 [17-1]

1. 의의

심판청구를 인용하는 재결은 피청구인과 그 밖의 관계 행정청을 기속한다. (행정심판법 제49조 제1항)

2. 재처분의무

거부처분 취소심판 등의 경우, 행정청은 재결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대한 처분을 하여야 한다.

(행정심판법 제49조 제2항)

의무이행심판의 경우, 행정청은 지체없이 이전의 신청에 대하여 재결의 취지에 따라 처분하여야 한다(제3항)

3. 재처분의무 불이행에 대한 권리구제수단

가. 직접처분

(1) 의무이행심판의 인용재결이 있었음에도 불구하고 처분을 하지 않는 경우, 당사자가 신청하면 기간을 정하여 서면으로 시정을 명하고 그 기간에 이행하지 아니하면 직접 처분할 수 있다 (행정심판법 제50조 제1항)

(2) 요건: 처분명령재결이 있었음 처분을 하지 않는 경우, 당사자가 신청하면 기간을 정하여 서면으로 시정을 명하고, 그 기간에 이행하지 아니하면 직접 처분(행정심판법 제50조 제1항 본문)

(3) 당해 행정청이 처분을 한 경우: 당해 행정청이 어떠한 처분을 하였다면 그 처분이 재결의 내용에 따르지 아니하였더라도 재결청이 직접 처분할 수 X

나. 간접강제

거부처분 취소심판 등 또는 의무이행심판의 인용 재결에 따른 처분을 하지 아니하면 청구인의 신청에 의하여 결정으로 상당한 기간을 정하고 피청구인이 그 기간 내에 이행하지 아니하는 경우 지연기간에 따라 일정한 배상을 명할 수 있다 (행정심판법 제50조의2 제1항)

☞ 관련쟁점

* 일부 인용재결 및 변경재결

원처분을 **유리하게 변경**하는 처분을 한 경우: 변경처분에 의하여 당초 처분은 소멸x, 당초부터 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하는 것이므로 **취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초 처분**

제6편 행정법 각론

제1장 행정조직법

<★★> 권한의 위임·위탁 [변6, 24-1, 18-2, 14-1]

일반규정에 따라 재위임 ○ 재위임-무효

권한없는 자에 의하여 행해진 위법무효의 처분

1. 의의

행정권한의 위임은 행정관청이 법률에 따라 특정한 권한을 다른 행정관청에 **이전**하여 **수임관청의 권한**으로 행사하도록 하는 것이다(判例)

2. 일반 규정에 근거한 위임의 허용 여부

문: 권한의 위임에 관하여 개별 법령에 규정이 없는 경우에 정부조직법 제6조, 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 제4조, 지방자치법 제117조의 일반 규정이 위임의 근거가 될 수 있는지 문제된다.

학: ①권한의 위임은 국민의 권리의무와 직접적인 관계가 없으므로 포괄적인 위임이 가능하고, 중앙행정기관의 권한을 지방자치단체에 이전할 필요도 없다는 **긍정설**, ②위 규정은 권한의 위임기준을 정하지않고 위임 또는 재위임이 가능하다는 원칙만 선언한 것이라는 **부정설**

판: 재위임에 관한 **일반적인 규정에 따라 위임받은 위 처분권한을 구청장 등에게 재위임할 수 있다**면서 **긍정설**

3. 재위임

가. 일반

위임을 받은 기관은 위임을 받은 사무의 일부를 재위임할 수 있는데(정부조직법 제6조 제1항 단서), 이 경우 ① 그 위임기관의 장의 승인을 받아야 하고, ②규칙에서 근거규정을 따로 정해야 한다. (행정위임위탁규정 제4조).

나. 조례에 의한 재위임

기관위임사무에 관하여 위임받은 권한을 행정위임위탁규정 제4조에 의하여 규칙을 제정해서 재위임하지 아니하고, **조례에 의하여 재위임**하였다면, 해당 조례 중 권한의 재위임에 관한 부분은 **조례제정권의 범위를 벗어난** 기관 위임사무를 대상으로 한 것이어서 **무효**이다.

4. 내부위임

가. 의의

내부위임이란 행정청의 내부적인 사무처리의 편의를 도모하기 위하여 보조기관 또는 하급행정관청으로 하여금 권한을 사실상 행사하게 하는 것을 말한다.

나. 수임관청의 명의로 이루어진 권한 행사의 효과

내부위임의 경우에는 수임관청은 위임관청의 이름으로만 그 권한을 행사할 수 있을 뿐 자기의 이름으로는 그 권한을 행사할 수 없는 것이므로, **권한 없는 자에 의하여 행하여진 위법무효**의 처분이다.

*피고: 처분명의자인 행정청

제2장 지방자치법

<★> 지방자치단체의 관할 구역 [15-1]
1. 지방자치단체의 구역 지방자치단체의 구역은 주민·자치권과 함께 지방자치단체의 구성요소로서 자치권을 행사할 수 있는 장소적 범위를 말하며, 자치권이 미치는 관할 구역의 범위에는 육지는 물론 바다도 포함되므로, 공유수면에 대한 지방자치단체의 자치권한이 존재한다(判例) .
2. 매립지의 경우 (지방자치법 제5조 제4항 이하) 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률에 따른 매립지가 속할 지방자치단체는 행정안전부장관이 결정한다(지방자치법 제5조 제4항 제1호) . 이 경우 매립면허관청 또는 관련 지방자치단체의 장 은 준공검사를 하기 전에 행정안전부장관에게 그 지역이 속할 지방자치단체의 결정을 신청하여야 한다(지방자치법 제5조 제5항). 행정안전부장관은 신청내용에 대하여 의의가 제기된 경우 지방자치단체중앙분쟁조정위원회의 심의 의결에 따라 매립지가 속할 지방자치단체를 결정한다(지방자치법 제5조 제7항 제1호). 관계 지방자치단체의 장 은 위 행정안전부장관의 결정에 의의가 있으면 그 결과를 통보받은 날로부터 15일 이내에 대법원에 소송을 제기할 수 있다(지방자치법 제5조 9항) .

제2절 지방자치단체 주민의 권리

<★> 주민의 감사 청구 [15-2]
1. 의의 지방자치단체의 18세 이상의 주민은 지방자치단체와 그 장의 권한에 속하는 사무의 처리가 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 인정되면 감사를 청구할 수 있다(지방자치법 제21조 제1항)
2. 요건 가. 주체(지방자치법 제21조 제1항) 해당 지자체의 관할 구역에 주민등록이 되어 있는 18세 이상의 주민으로서 지자체의 조례로 정하는 수 이상의 주민이 연대 서명하여 감사를 청구할 수 있다. 나. 대상 지방자치단체와 그 장의 권한에 속하는 사무처리가 법령 위반 또는 공익을 현저히 해하는 경우 감사를 청구할 수 있다(지방자치법 제21조 제1항). 다. 감사기관 시·도에서는 주무부장관, 시·군 및 자치구에서는 시·도지사
3. 범위와 한계 가. 대상사무 당해 지방자치단체 또는 그 장이 행하는 일체의 사무(자치사무, 단체위임사무, 기관위임사무) 나. 감사청구의 제외사유 ① 수사 또는 재판에 관여하게 되는 사항, ② 개인의 생활을 침해할 우려가 있는 사항, ③ 다른 기관에서 감사하였거나 감사중인 사항, ④ 동일한 사항에 대하여 제22조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 소송이 계속 중이거나 그 판결이 확정된 사항은 제외된다 (지방자치법 제21조 제2항).
다. 감사청구기간 사무처리가 있었던 날이나 끝난 날부터 3년이 지나면 제기할 수 없다(지방자치법 제21조 3항).
4. 효과 주무부장관이나 시도지사는 감사 청구를 수리한 날부터 60일 이내에 감사 청구된 사항에 대하여 감사를 끝내야 하며, 감사 결과를 청구인의 대표자와 해당 지방자치단체의 장에게 서면으로 알리고, 공표하여야 한다(제21조9항)

<★> 주민소송 [변10] 감사 청구한 사항과 관련

1. 의의

① 공금의 지출에 관한 사항, ②재산의 취득·관리·처분에 관한 사항, ③해당 지방자치단체를 당사자로 하는 매매·임차·도급 계약이나 그 밖의 계약의 체결 이행에 관한 사항 또는 ④지방세·사용료·수수료·과태료 등 공금의 부과·징수를 게을리 한 사항을 감사 청구한 주민은 그 **감사 청구한 사항과 관련**이 있는 위법한 행위나 업무를 게을리한 사실에 대하여 해당 지방자치단체의 장을 상대방으로 하여 소송을 제기할 수 있다(**지방자치법 제22조 제1항**).

判) 주민소송은 원칙적으로 지방자치단체의 재무회계에 관한 사항의 처리를 직접 목적으로 하는 행위에 대하여 제기할 수 있고, 특히 도로 등 공물이나 공공용물을 특정 사인이 배타적으로 사용하도록 하는 점용허가가 도로 등의 본래 기능 및 목적과 무관하게 그 사용가치를 실현·활용하기 위한 것으로 평가되는 경우에는 주민소송의 대상이 되는 재산의 관리·처분에 해당한다.

2. 요건

①주무부장관이나 시·도지사가 감사 청구를 수리한 날부터 60일이 지나도 감사를 끝내지 아니한 경우, ②감사 결과 또는 조치 요구에 불복하는 경우, ③주무부장관이나 시·도지사의 조치 요구를 지방자치단체의 장이 이행하지 아니한 경우, ④지방자치단체의 장의 이행조치에 불복하는 경우 중 어느 하나에 해당(**지방자치법 제22조 제1항**)

3. 종류

①손해발생행위 중지청구소송, ②처분취소 또는 무효 등 확인소송, ③해태사실위법확인소송, ④지자체장 등 해당 행위와 관련이 있는 상대방에 대한 손해배상 또는 부당이득반환청구소송 등이 있다(**제22조 제2항**).

<★> 그 밖의 권리 [변11]

1. 조례의 제정과 개정 폐지 청구

주민은 지방자치단체의 조례를 제정·개정·폐지할 것을 청구할 수 있다(**지방자치법 제19조 제1항**)

2. 청원권

지방의회에 청원을 하려는 자는 지방의회의원의 소개를 받아 청원서를 제출할 수 있다(**지방자치법 제85조 1항**)

<★★★> 지방자치단체의 사무와 배분 [변13, 7, 23-1 등] **법치전경책임**

1. 지방자치단체의 사무

자치사무: 지방자치단체의 본래의 목적으로 예정된 사무
 단체위임사무: 국가나 다른 공공단체가 법령에 근거하여 **지방자치단체에** 구체적으로 위임한 사무
 기관위임사무: 법령에 근거하여 **지방자치단체의 집행기관**(지방자치단체의 장)에게 위임한 다른 행정주체의 사무
 이때 기관위임사무를 처리하는 지방자치 단체의 기관은 국가 등의 행정기관으로서의 지위를 갖게 된다.

☞ 주의: 지자체 ≠ 지자체장

2. 사무의 구별기준 **법.치(취).전.경.책.임**

법령상 지방자치단체의 장이 처리하도록 규정하고 있는 사무가 자치사무인지 기관위임사무에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 ①그에 관한 **법령의 규정 형식**과 ②**취지**를 우선 고려하여야 할 것이지만 그 외에도 ③그 사무의 성질이 **전국적으로 통일적인 처리**가 요구되는 사무인지 여부나 ④그에 대한 **경비부담**과 ⑤**최종적인 책임귀속의 주체** 등도 아울러 고려하여 판단하여야 한다(判例)

判) 전국적으로 통일적 처리를 요하는 **학교생활기록의 작성에 관한 사무**에 대한 감독관청의 지도 감독 사무도 국민 전체의 이익을 위하여 통일적으로 처리되어야 할 성격의 사무라고 보아야 하므로, 공립 사립학교의 장이 행하는 학교생활기록부 작성에 관한 교육감의 지도 감독 사무는 **국가사무**로서 교육감에 위임된 사무이다.

<★★> 조례제정권 [변4, 24-2, 20-3, 16-1]

1. 의의

지방자치단체는 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다(지방자치법 제28조 제1항 본문). 여기서 '그 사무'는 자치사무와 법령에 따라 지방자치단체에 속하는 단체위임사무를 말한다(지방자치법 제13조 제1항)

2. 위임조례

국가사무가 지방자치단체의 장에게 위임된 기관위임사무는 원칙적으로 자치조례의 제정범위에 속하지 않지만, 개별법령에서 일정한 사항을 조례로 정하도록 위임하고 있는 경우에는 위임받은 사항에 관하여 개별법령의 취지에 부합하는 범위 내에서 이른바 위임조례를 정할 수 있다

3. 조례제정권의 범위와 한계 (우.유.침)

가. 법령우위의 원칙

判) 지방자치단체는 법령의 범위에서 조례를 제정할 수 있는데(헌법 제117조 제1항, 지방자치법 제28조 제1항 본문), '법령의 범위에서'라는 의미는 '법령에 위반되지 아니하는 범위'라는 의미로 풀이된다.

判) 법령의 규정보다 더욱 침익적인 조례는 무효인 반면, 국가법령의 취지가 지방자치단체의 실정에 맞도록 별도 규율을 용인하려는 것이라면 국가법령보다 더 수익적인 조례의 적법성을 인정하고 있다.

*判) 특별한 규정이 없는 한 지방자치법이 규정하고 있는 지방자치단체의 집행기관과 지방의회의 고유권한에 관하여는 조례로 이를 침해할 수 없고, 나아가 지방의회가 지방자치단체장의 고유권한이 아닌 사항에 대하여도 그 사무집행에 관한 집행권을 본질적으로 침해하는 것은 지방자치법의 관련 규정에 위반되어 허용될 수 없다

나. 법률유보의 원칙

주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다(28조1항 단서)
*判) 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률의 위임에 따라 닭의 가축사육제한구역은 주거밀집지역으로부터 900m로 규정한 조례 사항은 위임조항의 주거밀집지역으로 생활환경의 보호가 필요한 지역을 그 의미 내에서 구체화한 것이고, 위임조항에서 위임한 한계를 벗어났다고 볼 수 없다.

다. 위임한계의 준수 여부

① 위임규정의 문언적 의미의 한계를 벗어났는지, ② 위임내용을 구체화하는 단계를 벗어나 새로운 입법을 했는지
라. 침익초과조례의 경우

법률의 위임 없이 주민의 권리 제한 또는 의무부과에 관한 사항을 정한 조례는 효력 X

마. 수익초과조례의 경우

국가의 법령이 이미 존재하는 경우에도, 각 지자체가 그 지방의 실정에 맞게 별도로 규율하는 것을 용인하는 취지라고 해석되는 때에는 그 조례가 국가의 법령에 위반되는 것은 아니다

<★★> 조례안 의결에 대한 재의와 제소 [변7, 21-1, 16-1]

1. 조례안 의결에 대한 재의

가. 지방자치단체장의 재의 요구

지방자치단체의 장은 지방의회 의결이 월권이거나 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 인정되면 그 의결사항을 이송받은 날부터 20일 이내에 이유를 붙여 재의를 요구할 수 있다(지방자치법 제120조 제1항).

나. 감독관청(주무부장관, 시도지사)의 재의 지시

지방의회의 의결이 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 판단되면 시도에 대해서는 주무부장관이, 시군 및 자치구에 대해서는 시도지사가 해당 지방자치단체의 장에게 재의를 요구하게 할 수 있고(지방자치법 제192조 제1항), 시도지사가 재의를 요구하게 하지 아니한 경우 주무부장관이 직접 재의를 요구하게 할 수 있다(지방자치법 제192조 제2항)

2. 조례안 재의결에 대한 지방자치단체 장의 제소

가. 지방자치단체의 장의 독자적인 제소

지자체장은 지방의회가 재의결한 사항이 법령에 위반된다고 인정되면 재의결된 날부터 20일 이내에 대법원에 소를 제기할 수 있다(지방자치법 제120조 제3항)

지방자치단체의 장은 이송받은 조례안에 대하여 이의가 있으면 제2항의 기간 내(이송후 20일) 이유를 붙여 지방의회로 환부하고, 재의결을 요구할 수 있다.(지방자치법 제32조 제3항)

문 : 제120조 1항과 제32조 3항의 관계?

판 : 제32조 제3항이 특별규정이므로 우선 적용

문: 제32조 3항 재의요구에 불구하고 원안대로 재의결된 경우, 제120조 제3항에 따라 제소 가능?

판: 제32조 3항은 재의요구권을 폭넓게 인정한 것이므로 조례안에 대한 재의결도 120조의 재의결에 당연 포함

나. 감독관청의 재의 지시 후 지방자치단체의 장의 제소

지방자치단체의 장은 감독관청의 재의 지시에 따른 지방자치단체의 장의 재의 요구에 따라 재의결된 사항이 법령에 위반된다고 판단되면 재의결된 날부터 20일 이내에 대법원에 소를 제기할 수 있다. 이 경우 필요하다고 인정되면 그 의결의 집행을 정지하게 하는 집행정지결정을 신청할 수 있다(지방자치법 제192조 제4항)

3. 조례안 재의결에 대한 감독관청의 제소

가. 지방자치단체의 장이 제소를 하지 않는 경우

① 지방자치단체의 장에게 제소를 지시, ② 직접제소 및 집행정지결정 신청(제192조 제5항).

나. 지자체장이 재의 요구를 하지 않는 경우

지방의회의 의결이 법령에 위반된다고 판단되어 감독관청의 재의 요구 지시를 받은 해당 지자체장이 재의를 요구하지 아니하는 경우 대법원에 직접 제소 및 집행정지결정 신청할 수 있다(제192조 제8항)

<★> 자주재정권 [모24-1]
지방자치단체는 그 재산 또는 공공시설의 설치로 주민의 일부가 특히 이익을 받으면 이익을 받는 자로부터 그 이익의 범위에서 분담금을 징수할 수 있다(지방자치법 제155조)
判)법인의 경우 해당 지방자치단체의 구역 안에 주된 사무소 또는 본점을 두고 있지 않더라도 '사업소'를 두고 있다면 구 지방자치법 제138조에 따른 분담금 납부의무자인 '주민'에 해당한다.

제5절 감독관청의 관여

<★★> 감독관청의 관여
I. 지도 감독
II. 명령 처분의 시정명령
III. 직무이행명령 및 대집행
IV. 자치사무에 대한 감사

<★> 지도·감독 [22-2]
지방자치단체나 그 장이 위임받아 처리하는 국가사무에 관하여, 시·도에서는 주무부장관, 시·군 및 자치구에서는 1차로 시·도지사, 2차로 주무부장관의 지도·감독을 받고(지방자치법 제185조 제1항), 시·군 및 자치구나 그 장이 위임받아 처리하는 시·도의 사무에 관하여는 시·도지사의 지도·감독을 받는다(지방자치법 제185조 제2항)
국가사무를 위임받아 처리 시·도 → 주무부장관 감독 시·군·구 → (1차) 시·도지사, (2차) 주무부장관
시·도 사무를 위임받아 처리 시·군·구 → 시·도지사 감독

<★> 명령·처분의 시정명령 [변13, 23-1, 19-2]
가. 의의 지방자치단체의 사무에 관한 지방자치단체의 장의 명령이나 처분이 법령에 위반되거나 현저히 부당하여 공익을 해친다고 인정되면 감독청은 ①기간을 정하여 서면으로 시정할 것을 명하고, ②그 기간에 이행하지 아니하면 이를 취소하거나 정지할 수 있다(지방자치법 제188조 제1항). 자치사무에 관한 명령이나 처분에 대한 주무부장관 또는 시·도지사의 시정명령, 취소 또는 정지는 법령을 위반한 것에 한한다.(188조5항) 지방자치단체의 사무에 관한 지방자치단체의 장의 명령이나 처분이 법령에 위반되는 경우 그러한 사무의 집행이 재량권을 일탈·남용하여 위법하게 되는 경우를 포함한다.(判例)
나. 소제기의 가능여부 지방자치단체의 장은 자치사무에 관한 명령이나 처분의 취소 또는 정지에 대하여 이의가 있으면 그 취소처분 또는 정지처분을 통보받은 날부터 15일 이내에 대법원에 소를 제기할 수 있다(지방자치법 제188조 제6항). 判)지방자치법 제188조 제6항은 자치사무에 관한 명령이나 처분의 취소 또는 정지에 대하여서만 소를 제기할 수 있다고 규정하고, 시정명령에 대하여도 대법원에 소를 제기할 수 있다는 규정을 두고 있지 않으므로, 시정명령의 취소를 구하는 소송은 허용되지 않는다.

<★> 직무이행명령 및 대집행 [모22-2]
지방자치단체의 장이 법령에 따라 그 의무에 속하는 국가위임사무나 시·도위임사무의 관리와 집행을 명백히 게을리하고 있다고 인정되면 시·도에 대해서는 주무부장관이, 시·군 및 자치구에 대해서는 시·도지사가 기간을 정하여 서면으로 이행할 사항을 명령할 수 있다(지방자치법 제189조 제1항). 주무부장관이나 시·도지사는 해당 지방자치단체의 장이 제1항의 기간에 이행명령을 이행하지 아니하면 그 지방자치단체의 비용부담으로 대집행 또는 행정상·재정상 필요한 조치를 할 수 있다(지방자치법 제189조 제2항). 지방자치단체의 장은 이행명령에 이의가 있으면 이행명령서를 접수한 날부터 15일 이내에 대법원에 소를 제기할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 이행명령의 집행을 정지하게 하는 집행정지결정을 신청할 수 있다(지방자치법 제189조 제6항).

<★> 자치사무에 대한 감사 [모23-1]
행정안전부장관이나 시도지사는 지방자치단체의 자치사무에 관하여 보고를 받거나 서류 장부 또는 회계를 감사할 수 있다. 이 경우 감사는 법령 위반사항에 대해서만 한다.(지방자치법 제190조 제1항)

제3장 공무원법
제1절 공무원관계

<★★> 직위해제 [21-3, 20-1]

징벌적 제재인 징계처분X 행정절차법X

1. 의의

직위해제란 공무원에게 당해 직무수행을 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우 그 보직을 해제하여 직무담임을 하지 못하게 하는 것을 말한다

(국가공무원법 제73조의3, 지방공무원법 제65조의3)

2. 직위해제의 성질

직위해제 제도는 '파면, 해임, 정직에 해당하는 징계의결이 요구' 중인 공무원이 계속 직위를 보유하고 직무를 수행한다면 공무집행의 공정성과 그에 대한 국민의 신뢰를 저해할 구체적인 위험이 생길 우려가 있으므로 이를 사전에 방지하고자 하는 데 그 목적이 있고, 이와 같은 직위해제처분은 징벌적 제재인 징계처분과는 그 성질을 달리하는 별개의 처분.

3. 직위해제의 요건

직위해제는 ①직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자, ②파면 해임 강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자, ③형사 사건으로 기소된 자 및, ④금품비위, 성범죄 등으로 인하여 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자를 대상으로 한다(국가공무원법 제73조의3 제1항, 지방공무원법 제65조의3 제1항)

*判) 원고가 근무기강을 해이하게 하였다는 사유는 국가공무원법 소정의 징계사유에 해당함은 별문제로 하고, 국가공무원법 소정의 직위해제사유인 '직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자'에 해당한다고는 볼 수 없다.

*判) 형사사건으로 기소되었다는 이유만으로 직위해제처분을 하는 것은 정당화될 수 없고, 당사자가 당연퇴직 사유인 유죄판결을 받을 고도의 개연성이 있는지 여부, 계속 직무를 수행함으로써 공정한 공무집행에 위험을 초래하는지 등 구체적 사정을 고려하여 위법여부 판단하여야.

4. 직위해제의 절차

국가공무원법상 직위해제처분은 당해 행정작용의 성질상 행정절차를 거치기 곤란하거나 불필요하다고 인정되는 사항 또는 행정절차에 준하는 절차를 거친 사항(행정절차법 제3조 제2항 제9호)에 해당하므로, 행정절차법의 규정이 별도로 적용되지 않는다.

<★> 행정심판의 전치

공무원에 대한 징계처분, 그 밖에 본인의 의사에 반한 불리한 처분이나 부작위에 관한 행정소송은 소청심사위원회의 심사결정을 거치지 아니하면 제기할 수 없다

(국가공무원법 제16조 제1항, 지방공무원법 제20조의2)

공무원의 의무

1. 복종의 의무

공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다(국가공무원법 제57조, 지방공무원법 제49조).

判) 공무원이 상급행정기관이나 감독권자의 직무상 명령을 위반하였다는 점을 징계사유로 삼으려면 그 직무상 명령이 상위법령에 반하지 않는 적법·유효한 것이어야 한다

2. 비밀 엄수의 의무

공무원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수하여야 한다(국가공무원법 제60조, 지방공무원법 제52조).

判) 직무상 비밀은 행정기관이 비밀이라고 형식적으로 정한 것에 따를 것이 아니라 실질적으로 비밀로서 보호할 가치가 있는지, 즉 ①그것이 통상의 지식과 경험을 가진 다수인에게 알려지지 아니한 비밀성을 가졌는지, 또한 ②정부나 국민의 이익 또는 행정목적 달성을 위하여 비밀로서 보호할 필요성이 있는지 등이 객관적으로 검토되어야 한다.

3. 품위 유지의 의무

공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니된다(국가공무원법 제63조, 지방공무원법 제55조)

判) 여기서 '품위'는 공직의 체면, 위신, 신용을 유지하고, 주권자인 국민의 수임을 받은 국민 전체의 봉사자로서의 직책을 다함에 손색이 없는 몸가짐을 뜻하는 것으로서, 직무의 내외를 불문하고, 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말한다.

임용결격과 당연퇴직

<★★> 퇴직급여의 제한 [변2]

임용 당시 공무원임용 결격사유가 있었다면 비록 국가의 과실에 의하여 임용결격자임을 밝혀 내지 못하였다고 하더라도 그 임용행위는 당연무효로 보아야 하고, 적법한 공무원으로서의 신분을 취득하지 못한 자는 공무원연금법 소정의 퇴직급여 등을 청구할 수 없다(判例)

判) 그러나 임용행위가 당연무효임에도 계속 근무하여 온 경우 임용시부터 퇴직시까지의 근로는 법률상 원인 없이 제공된 부당이득이므로, 적어도 근로기준법상 퇴직금에 상당하는 금액은 그가 재직기간 중 제공한 근로에 대한 대가로서 지급되어야 한다.

判) 그리고 부당이득은 손해액과 이득액 중 적은 범위 내에서 반환의무를 지므로, 손해액에 해당하는 공무원연금법상 기여금 관련 금액 및 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직금 상당액의 합계가 공무원연금법상 퇴직급여 상당액을 넘는 경우에, 국가 또는 지방자치단체가 반환하여야 할 부당이득액은 공무원연금법상 퇴직급여 상당액으로 제한된다.

제4장 개별행정법

제1절 공물법

공공공물의 의의 및 성립
1. 공물의 의의
가. 개념
공물은 ①행정주체에 의하여 또는 관습법에 의하여 ②직접 ③공적 목적에 제공된 ④유체물과 무체물 등을 말한다. 공물은 그 목적에 따라 공공용물, 공용물, 보존공물로 분류된다.
국공유재산은 그 용도에 따라 행정재산과 일반재산으로 구분한다(국유재산법 제6조 제1항), 행정재산 중 ①공용재산은 공용물에 해당하고, ②공공용재산은 공공용물에 해당하며, ③보존용재산은 보존공물에 해당한다.
나. 공공용물(공공용재산)
도로·하천·항·만·운하·제방·교량·공원·천연기념물 등과 같이 국가나 지방자치단체가 일반공중의 공공사용을 위하여 제공한 재산을 말한다.
다. 공용물(공용재산)
행정기관의 건물, 집기, 비품 등과 같이 국가나 지방자치단체가 자신의 사용을 위하여 제공한 재산을 말한다.
라. 보존공물(보존용재산)
중요문화재 등과 같이 오직 공공의 목적을 위하여, 법령이나 그 밖의 필요에 따라 국가가 보존하는 재산을 말한다.
2. 공공공물의 성립
가. 공용지정(공용개시)
공공공물이 성립하기 위해서는 ①일반공중의 사용에 제공될 수 있는 형태를 갖추어야 하고, ②일반공중의 사용에 제공한다는 행정주체의 의사적행위(공용지정)가 필요.
공용지정이란 권한을 가진 기관이 어떠한 물건이 특정한 공적 목적에 봉사한다는 것과 그 때문에 특별한 공법상의 이용질서하에 놓인다는 것을 선언하는 법적 행위를 말한다.
나. 인공공물의 공용지정
도로와 같은 이른바 인공적 공공용 재산은 ①법령에 의하여 지정되거나 ②행정처분으로 공공용으로 사용하기로 결정한 경우, ③행정재산으로 실제 사용하는 경우의 어느 하나에 해당하면 행정재산이 되는 것이다(判例)
*判) 도로는 도로로서의 형태를 갖추고, 도로법에 따른 노선의 지정 또는 인정의 공고 및 도로구역 결정·고시를 한 때 또는 도시계획법 또는 도재개발법의 절차를 거쳐 도로를 설치하였을 때에, 토지의 지목이 도로이고 국유재산대장에 등재되어있다는 사정만으로 바로 그 토지가 도로로서 행정재산에 해당한다고 할 수는 없다
다. 자연공물의 공용지정
국유하천부지는 자연의 상태 그대로 공공용에 제공될 수 있는 실체를 갖추고 있는 이른바 자연공물로서 별도의 공용개시행위가 없더라도 행정재산이 된다.

<★> 공물의 소멸
1. 공용폐지
공용폐지는 해당 공물에 대하여 공적 목적에의 공용을 폐지시키는 행위를 말한다.
判) 공용폐지의 의사표시는 명시적 의사표시뿐만 아니라 묵시적 의사표시도 무방하다.
2. 공물의 시효취득 ★ [13-3]
학: ①공물 본래의 목적에 어긋나므로 인정할 수 없다는 부정설, ②시효취득의 대상이 될 수 있으나 계속 공적 목적에 공용할 법적 제한이 붙은 채로 소유권을 취득한다는 제한적 시효취득설.
판: 행정재산은 공용폐지가 되지 아니하는 한 사법상 거래의 대상이 될 수 없으므로 시효취득의 대상이 되지 않는 다면서 부정설의 입장이다.
*判) 공용폐지의 의사표시는 명시적이든 묵시적이든 상관 없이 적법한 의사표시가 있어야 하고, 행정재산이 사실상 본래의 용도에 사용되지 않고 있다는 사실만으로 용도폐지의 의사표시가 있었다고 볼 수는 없으며, 원래의 행정재산이 공용폐지되어 취득시효의 대상이 된다는 사실에 대한 입증책임은 시효취득을 주장하는 자에게 있다.

공물의 사용관계
공물의 사용관계는 ①도로의 통행, 공원의 산책과 같이 누구든지 행정청의 허락을 받지 않고 그 사용목적에 따라 사용하는 일반사용, ②관리목적상 또는 경찰목적상 일정한 공물의 사용을 일반적으로 금지시킨 다음 행정청의 허가를 받아 사용하도록 하는 허가사용, ③공물주체가 특정인에게 일정한 내용의 공물사용권을 설정하여 줌으로써 당해 공물을 독점적으로 이용하는 특허사용 등으로 구분된다.
*判) 하천의 점용허가권은 특허에 의한 공물사용권의 일종으로서 하천의 관리주체에 대하여 일정한 특별사용을 청구할 수 있는 채권에 지나지 아니하고 대세적 효력이 있는 물권이라 할 수 없다.
*判) 일반적으로 도로는 국가나 지방자치단체가 직접 공중의 통행에 제공하는 것으로서 일반국민은 이를 자유로이 이용할 수 있는 것이기는 하나, 그렇다고 하여 그 이용관계로부터 당연히 그 도로에 관하여 특정한 권리나 법령에 의하여 보호되는 이익이 개인에게 부여되는 것이라고까지는 말할 수 없으므로, 일반적인 시민생활에 있어 도로를 이용만 하는 사람은 그 용도폐지를 다룰 법률상의 이익이 없다.

<★★> 행정재산의 목적외 사용 [20-2, 13-2]

조 : 행정재산은 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위 내에서 사용허가를 할 수 있다(국유재산법 제30조 제1항, 공유재산 및 물품관리법 제20조)

학 : ①행정재산의 사용·수익은 오로지 사용·수익하는 자의 사적 이익을 도모하는 데 있으므로 사법상의 계약의 성질을 갖는다는 **사법관계설**, ②현행 국유재산법이 행정재산의 사용에 대하여 명문으로 '허가'를 받도록 규정하고 있으므로 행정행위의 성질을 가진다는 **공법관계설**, ③사용·수익관계의 발생·소멸과 사용료의 징수관계는 공법관계이나, 행정재산의 사용·수익관계는 사법관계라는 **이원적 법률관계설**.

판 : 국유재산 등의 관리청이 하는 행정재산의 사용·수익에 대한 허가는 순전히 사경제주체로서 행하는 사법상의 행위가 아니라 관리청이 공권력을 가진 우월적 지위에서 행하는 행정처분으로서 **강학상 특허**에 해당한다면서, **공법관계설**의 입장이다.

제2절 공용수용

공용수용

1. 의의

공용수용이란 특정한 공익사업을 위하여 법률에 의거하여 타인의 토지 등의 재산권을 강제적으로 취득하는 것을 말한다.

2. 공용수용의 절차 (1) 사업의 준비 >

(2) 사업인정

공익사업을 토지등을 수용하거나 사용할 사업으로 결정하는 것을 말한다(공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제2조 제7호, '토지보상법').

判) 해당사업이 외형상 토지 등을 수용 또는 사용할 수 있는 사업에 해당한다고 하더라도 사업인정기관으로서 그 사업이 공용수용을 할 만한 공익성이 있는지의 여부와 공익성이 있는 경우에도 그 사업의 내용과 방법에 관하여 사업인정에 관련된 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서는 물론, 공익 상호간 및 사익 상호간에도 정당하게 비교·교량하여야 하고, 그 비교·교량은 비례의 원칙에 적합하도록 하여야 한다. , > (3) 토지조서·물건조서의 작성 >

(4) 협의

사업인정을 받은 사업시행자는 토지조서 및 물건조서의 작성, 보상계획의 공고·통지 및 열람, 보상액의 산정과 토지소유자 및 관계인과의 협의 절차를 거쳐야 한다(토지보상법 제26조 제1항 본문.)

*判) 공공사업의 시행자가 토지수용법에 의하여 그 사업에 필요한 토지를 취득하는 경우 그것이 ①**협의에 의한 취득**이고 ②공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률상의 **협의 성립의 확인이 없는 이상**, 사경제주체로서 행하는 사법상의 취득으로서 **승계취득**한 것으로 보아야 할 것이고 원시취득으로 볼 수 X

재결

가. 재결신청

협의를 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 사업시행자는 사업인정고시가 된 날부터 1년 이내에 토지수용위원회에 재결을 신청할 수 있다(토지보상법 제28조 제1항)

나. 재결신청의 청구

사업인정고시가 된 후 협의가 성립되지 아니하였을 때에는 토지소유자와 관계인은 서면으로 사업시행자에게 재결을 신청할 것을 청구할 수 있다(토지보상법 제30조 제1항)

다. 재결의 효과

토지수용위원회의 재결이 있으면 ①사업시행자는 보상금의 지급 또는 공탁을 조건으로 수용의 개시일에 토지에 대한 권리를 원시취득하고, ②피수용자는 목적물을 인도 또는 이전할 의무를 지는 반면에, 손실보상청구권 및 환매권을 취득한다.

<★★> 재결에 대한 불복 [변9, 13-3, 12-3]

가. 이의신청

중앙토지수용위원회의 수용재결에 이의가 있는 자는 중앙토지수용위원회의 이의를 제기할 수 있다(토지보상법 83조1항)

지방토지수용위원회의 수용재결 → 지방토지수용위원회를 거쳐 중앙토지수용위원회의 이의 신청 可(83조 2항)

재결서의 정본을 받은 날부터 30일 이내에 하여야.

중앙토지수용위원회는 이의신청을 받은 경우 수용재결이 위법하거나 부당하다고 인정할 때에는 ①그 **재결의 전부 또는 일부를 취소**하거나 ②**보상액을 변경**할 수 있다(제84조 1항)

나. 행정소송

사업시행자, 토지소유자 또는 관계인은 **수용재결에 불복**할 때에는 재결서를 받은 날부터 90일 이내에, 이의신청을 거쳤을 때에는 이의신청에 대한 재결서를 받은 날부터 80일 이내에 각각 행정소송을 제기할 수 있다(토지보상법 제85조 1항)

***보상금증감청구소송:** 행정소송이 **보상금의 증감에 관한 소송**인 경우 그 소송을 제기하는 자가 토지소유자 또는 관계인일 때에는 사업시행자를, 사업시행자일 때에는 토지소유자 또는 관계인을 각각 피고로 한다(토지보상법 제85조 제2항). 보상금증감에 관한 소송을 **형식적 당사자소송**에 의하도록 한 것이다.

손실보상

1. 원칙

공익사업에 필요한 토지등의 취득 또는 사용으로 인하여 토지소유자나 관계인이 입은 손실은 사업시행자가 보상하여야 한다(토지보상법 제61조)

2. 직접손실

보상액의 산정은 협의에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다(토지보상법 제67조 제1항).

보상액을 산정할 경우에 해당 공익사업으로 인하여 토지등의 가격이 변동되었을 때에는 이를 고려하지 아니한다(토지보상법 제67조 제2항).

3. 간접손실

가. 의의

공익사업이 시행되는 지역 밖에 있는 토지등이 공익사업의 시행으로 인하여 본래의 기능을 다할 수 없게 되는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 손실을 보상하여야 한다(토지보상법 제79조 제2항)

나. 요건

① 공익사업의 시행으로 인하여 사업지구 밖에서 간접손실이 발생하리라는 것을 쉽게 예견할 수 있고 ② 그 손실의 범위도 구체적으로 특정할 수 있는 경우라면, 그 손실의 보상에 관하여 간접보상 규정을 유추적용할 수 있다.

***判)** 공익사업시행지구 밖 영업손실보상의 특성과 헌법이 정한 정당한 보상의 원칙에 비추어 보면, **공익사업시행지구 밖 영업손실보상**의 요건인 '공익사업의 시행으로 인한 그 밖의 부득이한 사유로 일정 기간 동안 휴업이 불가피한 경우'란 공익사업의 시행 또는 시행 당시 발생한 사유로 휴업이 불가피한 경우만을 의미하는 것이 아니라 공익사업의 시행 결과, 즉 그 **공익사업의 시행으로 설치되는 시설의 형태·구조·사용 등에 기인하여 휴업이 불가피한 경우도 포함된다.**

<★> 잔여지 등의 매수 및 수용 청구 [변14]

4. 잔여지 등의 매수 및 수용청구

가. 의의

동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 ① **사업시행자에게** 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, ② **사업인정 이후**에는 관할 **토지수용위원회에 수용을 청구**할 수 있다(토지보상법 제74조 제1항).

나. 법적 성질

잔여지 수용청구권은 손실보상의 일환으로 토지소유자에게 부여되는 권리로서 그 요건을 구비한 때에는 잔여지를 수용하는 토지수용위원회의 재결이 없더라도 그 청구에 의하여 수용의 효과가 발생하는 **형성권적 성질**을 가진다.

다. 권리구제 방법

잔여지 수용청구를 받아들이지 않은 토지수용위원회의 재결에 대하여 토지소유자가 불복하여 제기하는 소송은 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제85조 제2항에 규정되어 있는 **'보상금의 증감에 관한 소송'**에 해당하여 **사업시행자를 피고**로 하여야 한다.

5. 생활보상

사업시행자는 공익사업의 시행으로 인하여 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 되는 자를 위하여 이주대책을 수립·실시하거나 이주정착금을 지급하여야 한다(토지보상법 제78조 제1항)

사업시행자는 이주대책기준을 정하여 위 이주대책대상자 중에서 이주대책을 수립·실시하여야 할 자를 선정하거나 그들에게 공급할 주택 등의 내용이나 수량 등을 정하는데 재량을 가진다. 그리고 이를 위해 사업시행자가 설정한 기준은 그것이 객관적으로 합리적이 아니라거나 타당하지 않다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 존중되어야 한다.

***判)** 사업시행자에게 이주대책의 수립·실시의무를 부과하고 있다고 하여 그 규정 자체만에 의하여 이주자에게 택지분양권이나 아파트 입주권 등을 받을 수 있는 구체적인 권리가 직접 발생하는 것이라고는 볼 수 **X**. 절차에 따라 이주자가 신청을 하고 사업시행자가 이를 받아들여 이주대책대상자로 확인·결정하여야만 비로소 구체적인 수분양권이 발생.

6. 환매권

공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 **필요없게 된 경우** 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인은 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 **토지를 환매할 수 있다(토지보상법 제91조 제1항).**

<★★★> 조합설립인가 [18-2, 17-1, 16-1]

설권적 처분, 특허설. 조합설립결의 부분만- 확인의 이익x. 이송

1. 추진위원회의 조합설립총회의 법적 성질

판: 주택재개발사업조합의 결의 x 주민총회 또는 토지 등 소유자 총회의 결의에 불과

☞ 사법상 합동행위. 민사소송의 대상.

2. 조합설립인가의 법적 성질 - 강학상 특허인지

문: 추진위원회의 조합설립 총회결의에 대한 관계행정청의 조합설립인가처분이 강학상 특허인지 인가인지 그 법적 성질

학: ① 조합설립결의 효력을 보충·완성한다고 보는 **인가설**, ② 행정주체로서 포괄적 지위를 창설하는 설권적 행위로 보는 **특허설**, ③ 특허와 인가의 성격을 동시에 갖는 것으로 보는 **특허·인가 복합체설**

판: 조합설립인가는 행정주체의 지위를 부여하는 일종의 **설권적 처분**이라고 판시하여 **특허설**

검: 조합설립인가로 조합이 성립하면 조합은 도시정비법상 사업시행주체가 되어 공법상 사단인 공공조합으로서 행정주체가 되므로 원칙적으로 **특허설**이 타당하다. 따라서 항고소송의 대상은 **조합설립인가**가 되고 피고는 **인가청**이 된다.

3. 조합설립결의를 다투는 방법

가. 조합설립인가 전 쟁송방법

조합설립결의의 무효확인을 구하는 **민사소송의 방법**으로 다투어야 한다. 이 경우 조합설립결의의 효력을 다투는 확인의 이익이 인정된다.

나. 조합설립인가 후 쟁송방법

행정청을 상대로 **조합설립 인가처분**의 취소 또는 무효확인을 구하는 항고소송의 방법으로 다투어야 한다.

조합설립결의는 처분의 사전절차로 처분에 흡수되므로 별도쟁송 대상이 아니므로, **조합설립결의의 부분만을 따로 떼어내어 효력 유무를 다투는 확인의 소는 특사x 한 확인의 이익 X**

다. 조합설립결의 무효확인 소 제기 시 법원의 조치

①관할법원으로 이송 후 법원의 허가를 얻어 조합설립인가처분에 대한 항고소송으로 변경될 수 있음을 고려하여 보면, ② 주택재건축정비사업조합 설립 무효확인청구 부분은 **행정법원으로 이송**함이 마땅하다.

4. 조합설립변경인가 총회결의를 다투는 방법

설립된 조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에 일정 정족수의 총회의결을 거쳐 시장·군수 등의 인가를 받아야 한다(**도시정비법 제25조 제5항**).

조합설립변경 인가 이전 조합설립변경에 대한 총회결의의 효력 등을 다투는 소송은 **공법상 당사자소송**이 된다 (**행정소송규칙 제19조 제3호 가목**). 이때 **피고는 권리주체인 조합**이 된다.

사업시행계획인가

1. 의의

사업시행자는 정비사업을 시행하려는 경우에는 제52조에 따른 사업시행계획서를 정관등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 **사업시행계획인가**를 받아야 하고, 인가받은 사항을 변경하거나 정비사업을 중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다(도시 및 주거환경정비법 제50조 제1항)

2. 법적 성질

가. 토지 등 소유자들이 조합을 설립한 후 인가를 받는 경우
判 구 도시 및 주거환경정비법에 기초하여 ① 주택재개발정비사업조합이 수립한 **사업시행계획은 관할 행정청의 인가·고시가 이루어지면** 이해관계인들에게 구속력이 발생하는 **독립된 행정처분**에 해당하고, ②관할 행정청의 사업시행계획 인가처분은 **사업시행계획의 법률상 효력을 완성시키는 보충행위(인가)**에 해당한다.

나. 토지 등 소유자들이 조합을 설립하지 않고 정비사업을 직접 시행하는 경우

토지 등 소유자들이 직접 시행하는 도시환경정비사업에서 토지 등 소유자들에 대한 사업시행인가처분은 단순히 사업시행계획에 대한 보충행위로서의 성질을 가지는 것이 아니라 구 도시정비법상 정비사업을 시행할 수 있는 권한을 가지는 **행정주체로서의 지위를 부여하는 일종의 설권적 처분**의 성격을 가진다.

3. 토지 등 소유자들이 조합을 설립한 후 인가를 받는 경우 쟁송형태

기본행위인 사업시행계획에는 하자가 없는데 보충행위인 인가처분에 고유한 하자가 있다면 그 인가처분의 무효확인이나 취소를 구하여야 할 것이지만, 인가처분에는 고유한 하자가 없는데 **사업시행계획에 하자가** 있다면 사업시행계획의 무효확인이나 취소를 구하여야 할 것이지만 사업시행계획의 무효를 주장하면서 곧바로 그에 대한 인가처분의 무효확인이나 취소를 구하여서는 아니된다.

<★>관리처분계획 [23-2]

1. 의의

사업시행자는 분양신청기간이 종료된 때에는 분양신청의 현황을 기초로 관리처분계획을 수립하여 시장·군수등의 인가를 받아야 하며, 관리처분계획을 변경·중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다(도시 및 주거환경정비법 제74조 제1항)

관리처분계획의 수립 및 변경은 총회의 의결을 거쳐야 한다(제45조 제1항 제10호)

2. 법적 성질

도시 및 주거환경정비법에 기초하여 ①주택재개발정비사업조합이 수립한 관리처분계획은 그것이 인가·고시를 통해 확정되면 이해관계인에 대한 구속적 행정계획으로서 독립적인 행정처분에 해당한다. ②이러한 관리처분계획을 인가하는 행정청의 행위는 조합의 관리처분계획에 대한 법률상의 효력을 완성시키는 보충행위(인가)이다

3. 쟁송 형태

가. 소의 대상

주택재건축정비사업조합이 수립한 관리처분계획에 대하여 관할 행정청의 인가·고시까지 있게 되면 관리처분계획은 행정처분으로서 효력이 발생하게 되므로, ①총회결의의 하자를 이유로 하여 행정처분의 효력을 다투는 항고소송의 방법으로 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, ②그와 별도로 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나에 불과한 총회결의 부분만을 따로 떼어내어 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 특사 없는 한 허용되지 않는다.

나. 소의 종류

도시 및 주거환경정비법상 행정주체인 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 조합 총회결의의 효력 등을 다투는 소송은 행정처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송으로서 그 소송결과에 따라 행정처분의 위법 여부에 직접 영향을 미치는 공법상 법률관계에 관한 것이므로, 이는 행정소송법상의 당사자소송에 해당한다(判)

학설/판례
I. 쟁점의 정리

논점의 정리

넓은 개념(쟁점 포함)

질문 압축 관련하여, 쟁점 문제된다.

II. 공식(1) []의 법적성질

공식(2) '이 사건 처분'의 위법/효력 여부

(위법성 정도까지 기재)

공식(3) 일반론 (ex. 소송요건 등)

III. 질문 형태

1. 의의 및 문제점 / 문제점

(1) 개념 (2) 조문 (3) 해당 쟁점이 "왜" 문제가 되는지?

설문의 분석

2. 쟁점이름

3. 사안의 경우(소결)

— 포섭의 3박자

설문의 일부

1) 설문 내용 + 2) 참조조문 + 3) 판례

핵심

IV. 설문의 해결

질문 / 한 줄 요약 / 질문 답

1. 문제점 — 설문 분석 능력
2. 쟁점명 — 암기 능력
3. 사안의 경우 — 포섭 능력

ex)

- 부령의 법적성질
 - 多 — 법규명령
 - 판례 — 행정규칙
- '이 사건 처분'의 법적성질

기록

1. 입증방법 서류는 아무거나 써도 됨

2. 보통 처분서

3. 피고 속초시장(행정청)O 속초시(행정주체) X

처분에 대해 다룰 때는 시장한테, 돈 달라고 할 때 (당사자 소송)은 속초시에
지자체를 상대로 소 제기할 경우(당사자 소송) 대표자 기재

4. 미성년자이므로 법정대리인 친권자

5. 청구취지는 처분서에 기재된 날짜로

|

|